

DIREITO ADMINISTRATIVO

PRINCÍPIOS E PODERES DA ADMINISTRAÇÃO



GRAN CURSOS
ONLINE

SUMÁRIO

Princípios e Poderes da Administração Pública	3
Capítulo 1.....	4
Princípios da Administração Pública	4
Definição de Princípio do Direito	5
Princípios Básicos	6
Princípios Constitucionais Expressos.....	10
Princípios Expressos na Lei n. 9.794/1999	18
Princípios Implícitos	23
Questões de Concurso – Lista 1.....	27
Gabarito – Lista 1.....	39
Questões Comentadas.....	40
Capítulo 2	51
Poderes da Administração.....	51
Questões de Concurso – Lista 2	73
Gabarito.....	89
Questões Comentadas	90

PRINCÍPIOS E PODERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Olá, amigo(a)!

Estamos iniciando nossa aula, que será dividida em dois momentos.

No **capítulo 1**, iremos abordar um tema muito recorrente em provas de concursos públicos: **Princípios da Administração Pública**.

No **capítulo 2**, trataremos dos **"Poderes da Administração Pública"**.

Vamos continuar adotando a metodologia proposta no início do nosso Curso de Direito Administrativo, incluindo na aula aspectos doutrinários relevantes e, sempre que for pertinente, trazendo a jurisprudência aplicável.

Ao final, teremos nossa bateria de exercícios, iniciando com algumas questões comentadas e concluindo com várias questões para fins de fixação do conteúdo.

Então, mãos à obra!

Boa aula e bons estudos!

Lisiane Brito

Capítulo 1

Princípios da Administração Pública

O **Regime Jurídico Administrativo**, já analisado anteriormente, fundamenta-se no confronto entre as **prerrogativas** que a lei dá ao Estado (em decorrência da Supremacia do interesse público sobre o privado) e as **restrições** impostas ao administrador (em decorrência da Indisponibilidade do Interesse Público).

Entendendo a lógica que rege essa **bipolaridade do Direito Administrativo**, veremos que ela acabou por conferir aos **princípios** um papel de grande relevância.

Lucas Rocha Furtado¹ faz uma ponderação interessante:

A importância dos princípios está no fato de que, em primeiro lugar, eles servem de parâmetro para a interpretação de todas as regras. Se determinado dispositivo legal ou regulamentar permitir mais de uma interpretação possível, deve-se optar por aquela que melhor realize os princípios.

Outra grande função dos princípios é a de apresentar soluções para questões não tratadas diretamente pelas regras. Se determinado agente público se depara com situação para a qual deve apresentar solução e existe regra jurídica que aponta de forma evidente a solução, deve ele seguir essa regra. Todavia, isso nem sempre ocorre. Quantas vezes vê-se o administrador diante de situação para a qual nem a lei, nem os regulamentos, nem a doutrina, nem qualquer outra fonte possível apresenta solução e ele é, por dever de ofício, chamado a tomar alguma medida ou decisão. Como proceder em situações como essas, tão comuns no serviço público?

A solução está na utilização dos princípios. Devido ao seu elevado nível de abstração, os princípios prestam-se a resolver questões e permitem que o administrador apresente soluções juridicamente fundamentadas.

Pois bem, amigo(a). Devemos ter em mente que o operador do Direito Administrativo deve sempre buscar uma solução que não afronte os princípios, nem cause conflito entre eles.

¹ FURTADO, Lucas Roch, Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007.

Vou criar uma situação hipotética, para facilitar o entendimento de como se dá a aplicação dos princípios na prática administrativa. Imagine uma determinada situação em que a norma permite a adoção de mais de uma conduta. Nesse caso, devemos optar por aquela que melhor atenda a eficiência. Mas, devemos ter o cuidado de, sob o pretexto de atender à eficiência, não se acaba por ignorar a legalidade. Ao interpretar a lei, o administrador deverá adotar a conduta mais eficiente, de maneira que atenda os dois princípios (legalidade e eficiência), e não somente um deles.

Alexandre Mazza² fala da dupla funcionalidade dos princípios, apontando o seguinte entendimento:

Os princípios do Direito Administrativo cumprem duas funções principais:

- a) função hermenêutica: se o aplicador do direito tiver dúvida sobre qual o verdadeiro significado de determinada norma, pode utilizar o princípio como ferramenta de esclarecimento sobre o conteúdo do dispositivo analisado;
- b) função integrativa: além de facilitar a interpretação de normas, o princípio atende também à finalidade de suprir lacunas, funcionando como instrumento para preenchimento de vazios normativos em caso de ausência de expresso regramento sobre determinada matéria.

Definição de Princípio do Direito

Uma das melhores definições de princípios do direito ainda é a que José Cretella Júnior³ nos dá:

Princípios de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais, típicas, que condicionam todas as estruturas subsequentes. Princípios, neste sentido, são os alicerces da ciência.

² MAZZA, Alexandre, *Manual de direito administrativo*. São Paulo: Saraiva. 2015

³ CRETILLA JÚNIOR, José, *Curso de direito administrativo*, Rio de Janeiro: Forense, 1986.

Celso Antônio Bandeira de Mello⁴ define princípio do direito como sendo

O mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.

Princípios Básicos

Quando examinamos o Regime Jurídico Administrativo, vimos que sua principal característica está na presença de prerrogativas conferidas à Administração, que são necessárias à realização do interesse público. Mas, para que o interesse público seja atendido de forma efetiva, deve-se respeitar duas regras básicas:

- 1) **supremacia do Interesse Público Sobre o Privado;**
- 2) **indisponibilidade dos Interesses Públicos.**

Estamos falando de **princípios essenciais**, no sentido de que, a partir deles, se constroem todos os demais!

Vamos à análise dos dois.

Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse Privado

Lucas Rocha Furtado⁵ nos ensina, acerca da Supremacia do Interesse Público sobre o privado, que

não existem interesses públicos presumidos ou ilimitados. Eles só existem após serem reconhecidos pela Constituição Federal ou por lei como tais, e necessariamente terão limites também fixados pela Constituição ou pela lei.

⁴ MELLO, Celso Antônio Bandeira de, *Elementos de Direito Administrativo*: RT, SP

⁵ Op.Cit.

Assim, caberá à Constituição ou à lei fazer um juízo valor acerca dos interesses em jogo e atribuir a alguns interesses (os públicos) supremacia sobre os demais. Concluindo esse trabalho de valoração, o legislador tem a função de dar a determinadas pessoas, principalmente ao Estado, algumas prerrogativas necessárias à realização desses interesses que foram reconhecidos pelos representantes do povo como os mais importantes.

Por exemplo: foi do legislador responsável pela elaboração da Lei n. 8.666/1993 a percepção de que a Administração Pública cumpriria melhor seus objetivos se tivesse a prerrogativa de alterar unilateralmente os contratos. Com isso, foi incluída naquela lei essa cláusula exorbitante, nos artigos 58, I e 65, I.

– Podemos identificar a Supremacia do Interesse Público sobre o privado nesse caso?

– Claro! O contratado, embora tenha interesses na contratação, sabe que seus interesses não podem se sobrepor ao interesse público defendido pela administração contratante e, com isso, está obrigado a aceitar possíveis alterações unilaterais feitas por ela. Pois bem, amigo(a), a Supremacia do Interesse Público sobre o privado está no exercício de prerrogativas públicas, que prevalecem sobre outros interesses, podendo até mesmo afastá-los.

Diante disso tudo, partimos de algumas premissas e chegamos a uma conclusão lógica.

1ª premissa: o Interesse da coletividade é supremo em face ao interesse dos particulares. Em hipótese alguma será permitido que o interesse de um indivíduo, ou um pequeno grupo de indivíduos, se sobreponha ao interesse de toda a coletividade.

2ª premissa: a Administração Pública é um instrumental de que o Estado dispõe para atingir seus fins de satisfação do Interesse da coletividade, que está acima dos interesses privados.

Conclusão lógica: a Administração precisa ter a **prerrogativa de impor restrições a direitos individuais, a fim de proteger o Interesse Público.**

Assim, sempre que houver necessidade, o Poder Público deve se valer dessa supremacia e adotar todas as medidas que julgar necessárias, ainda que isso signifique prejuízo a interesses privados. É o que ocorre, por exemplo, na desapropriação de bens particulares, nas cláusulas exorbitantes dos Contratos Administrativos e em alguns atributos especiais que os atos administrativos possuem.

Nesse ponto, alguém poderia questionar:

– Tudo bem, mas há limites? 

A resposta é:

– Sim, claro que há limites! E esses limites se encontram justamente no segundo “ pilar ” do regime jurídico administrativo.

A realização do interesse público não se resume à noção de supremacia, mas abrange também a ideia de **indisponibilidade do interesse público.**

Indisponibilidade do Interesse Público

O Interesse Público é indisponível. Ele pertence ao POVO, não ao administrador.

Conforme leciona Lucas Furtado⁶, *“pensar em indisponibilidade importa cobrar do agente público ou privado, responsável pelo exercício da prerrogativa, fidelidade aos fins visados pelos criadores dessa prerrogativa”*.

Sim, porque as prerrogativas, como vimos, são criadas pela Constituição Federal ou por leis, cabendo aos que as aplicam verificarem quais são os fins a serem alcançados e os motivos que levaram o legislador a criar tais prerrogativas. Feito isso, deverão agir de modo que sejam alcançados os fins visados.

⁶ Op.Cit.

O regime jurídico-administrativo deve impor ao administrador algumas regras e restrições, a fim de evitar que ele abra mão do Interesse Público e corra atrás de interesses privados. Não há liberdade para o aplicador da lei dispor livremente dos bens e interesses da coletividade. Cabe a ele guardar e preservar tais bens e interesses, administrá-los de forma transparente, prestando conta dessa administração.

Um exemplo da aplicação prática do princípio da indisponibilidade dos bens e interesses públicos é o que dispõe o artigo 17 da Lei n. 8.666/1993, que estabelece regras para a alienação de bens públicos.

Vejamos:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I – Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:

Ah, agora sim as coisas estão ficando claras!



Muito bem, agora que as coisas estão clareando, vamos avançar um pouco no tema “Princípios do Direito Administrativo”.

Antes de mais nada, preciso te dar uma informação importante. Guarde bem isso:

Todos os princípios do Direito Administrativo têm origem constitucional. Alguns deles são denominados **princípios constitucionais expressos**, outros são **princípios constitucionais implícitos**, mas todos eles decorrem da Constituição Federal!

Princípios Constitucionais Expressos

São mencionados explicitamente no *caput* do art. 37 da Constituição de 1988.

Vejamos

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]

Apenas para efeito de memorização, guarde esta sigla:

"L. I. M. P.E."

LEGALIDADE,
IMPESSOALIDADE,
MMORALIDADE,
PUBLICIDADE,
EFIICIÊNCIA

Legalidade

Este princípio é característico dos Estados de Direito, por ser uma garantia de respeito, por parte do Estado, aos direitos individuais. Na medida em que a lei estabelece direitos, ela mesma traça limites para a qualquer atuação da Administração Pública que vise à restrição do exercício desses direitos, como uma forma de proteção aos particulares. Nesse cenário de legalidade, podemos afirmar que **a vontade da Administração pública é a que resulta da lei.**

Nesse ponto é importante que o estudante do Direito Administrativo saiba desvincular o raciocínio do direito público daquele aplicável ao direito privado.

No campo do Direito Administrativo, a doutrina vem admitindo a existência de dois princípios da legalidade.

O primeiro é a Legalidade prevista no art. 5º da Constituição, que permite a todos os particulares fazer tudo aquilo que não é proibido por lei. Nós, privados, temos a garantia constitucional que nos permite agir da maneira que bem entendermos, desde que isso não contrarie a lei. Um particular não pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, porque somente ela, a lei formal, aprovada pelo Legislativo, pode criar obrigações ou direitos a um particular, impondo a esse o dever de agir ou de se abster de fazer alguma coisa.

Essa legalidade, do direito privado, é também chamada “princípio da reserva de lei”.

A segunda versão do princípio da legalidade tem o sentido de subordinação à lei. O administrador público atua sempre que houver permissivo legal.

É a **legalidade administrativa**, prevista no art. 37, *caput*, da Constituição de 1988.

Não havendo permissão legislativa, não pode haver atuação administrativa. O silêncio legislativo não permite a atuação do administrador!

Impessoalidade

Na concepção clássica de Hely Lopes Meirelles⁷, o princípio da impessoalidade nada mais é do que o clássico princípio da **finalidade**. A doutrina mais atual já nos informa que devemos analisá-lo sob dois prismas.

Então vamos lá. Primeiramente, vamos ver a doutrina tradicional, depois a visão mais moderna. Ambas estão corretas e você deve estar preparado para provas que abordem qualquer uma delas!

⁷ MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 33a ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

A princípio, vamos entender impessoalidade como **não discriminação**. A doutrina tradicional nos traz essa ideia, de atuação não discriminatória. São critérios objetivos, não pessoais, que movem a atuação do administrador. Quando esse atua, não enxerga as pessoas que serão atingidas pelo ato, pois não pode agir de forma pessoal, seja para beneficiá-las, seja para prejudicá-las. Assim, o princípio da **impessoalidade, no seu sentido clássico, significa não discriminação**.

Mas a doutrina moderna vem apontando outro sentido, e isso vem sendo cobrado em provas!

Na abordagem moderna, a impessoalidade deve ser analisada agora sob a ótica do administrador. Os que assim a interpretam afirmam que, quando um ato administrativo é praticado, não se deve ver a pessoa do agente, e sim o Estado atuando por meio desse agente. É o que diz a **teoria do órgão**, também conhecida como **teoria da imputação**, que veremos mais adiante detalhadamente. Por ora, basta entender que, para essa faceta da impessoalidade, a atuação Estatal é exercida por meio dos órgãos e agentes públicos e, conseqüentemente, a responsabilidade deve ser imputada ao próprio Estado.

Muito bem, sobre impessoalidade é o que temos a dizer. Trata-se de um dos princípios constitucionais expressos, o qual impõe ao agente público uma atuação livre de quaisquer discriminações, sejam elas benéficas ou prejudiciais e exige que essa atuação seja pautada pela objetividade, visando sempre a finalidade pública do ato (doutrina clássica). Por outro lado, a atuação da Administração Pública não deve ser imputada à pessoa do agente público que a realiza, mas ao próprio Estado. Isso porque o Estado atua através de seus agentes, que atuam com impessoalidade.

– Fácil até aqui, não? Sim, muito tranquilo. Então vamos em frente. Passemos ao próximo princípio constitucional expresso.

Moralidade

Hely Lopes Meirelles⁸ avisa que não devemos confundir a moralidade administrativa com a moral do senso comum.

A moralidade do senso jurídico não se confunde com a moral social, do senso comum, sob pena de haver certa confusão, pois a moral social varia de lugar para lugar, de época para época.

Só a título de exemplo, deixe-me citar um artigo de lei. Vamos ver o art. 132 da Lei n. 8.112/1993, que trata da demissão dos servidores públicos da União. Esse artigo, ao tratar dos casos de demissão, aponta a hipótese de “conduta escandalosa ou incontinência pública na repartição”.

Pois bem, eu pergunto:

– Essa regra do art. 132 da Lei n. 8.112/1993, que prevê a demissão do servidor público, é decorrência do princípio da moralidade?

– Não. É decorrência da moralidade social. Essa demissão não decorre do princípio da moralidade previsto no *caput* do art. 37 da Constituição, pois esse é relativo à moral jurídica, que, por sua vez, se vincula à ideia de ética, probidade, não corrupção. Não se confunde com a moral social.

Aqui, como princípio que dever reger toda a atuação da Administração, tratamos da **moralidade jurídica**. Nesse sentido, a moralidade significa **ética, decoro e boa-fé**, estando diretamente vinculada à probidade no trato com a coisa pública e no combate à corrupção.

– **Interessante, não é?**

Ok, vamos em frente. Próximo princípio:

⁸ Op. Cit.

Publicidade

Devemos entender a publicidade, como princípio constitucional expresso, no sentido de **TRANSPARÊNCIA** na atuação administrativa. A publicidade viabiliza o controle social dos atos da Administração, pois, se a atividade é sigilosa, não há como ser controlada.

Além de ser um meio de viabilização do controle, a publicidade é **requisito de eficácia dos atos**. Um ato administrativo só pode produzir seus efeitos externos após sua publicação.

Mas, lembre-se de que não devemos encarar a publicidade de forma absoluta. Devemos analisar cada caso concreto, pois o sigilo é admitido em algumas circunstâncias. A própria Lei n. 12.527/2011, denominada "Lei de Acesso à Informação", traz em seu texto hipóteses de sigilo. Mas, para que esse seja lícito, é necessário que um dos seguintes pressupostos se faça presente:

- Relevante interesse coletivo;
- Garantia de segurança nacional;
- Proteção à intimidade, honra e vida privada.

O texto constitucional prevê algumas exceções ao princípio da publicidade. O art. 5º, XXXIII, dispõe que

Art. 5º

XXXIII – todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Outro inciso do mesmo artigo permite alguma restrição à publicidade dos atos. Trata-se do inciso LX, a seguir:

Art. 5º

LX – A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem

Entretanto, devemos lembrar que não cabe ao administrador estabelecer regras de sigilo. Somente a lei pode fazê-lo.

A regra é que o ato administrativo seja levado ao conhecimento público, ressalvadas as hipóteses de sigilo legalmente previstas.

Eficiência

É o mais novo dos princípios constitucionais expressos, incluído no art. 37 da Constituição Federal dez anos após sua promulgação, com a Emenda Constitucional 19 de 1998, conhecida como “Reforma Administrativa Brasileira”.

Em um primeiro momento, a doutrina chegou a dizer que se tratava de um princípio fluido, que só teria aplicabilidade no caso concreto quando uma lei viesse a regulamentá-lo.

Hoje, entretanto, não é esse o entendimento. A doutrina hoje é unânime em afirmar que é uma norma de eficácia plena, de aplicabilidade imediata.

O princípio da eficiência exige que a atuação da Administração Pública seja pautada pela busca de resultados positivos. Caso o ato não seja apto a produzir tais resultados, não deve ser praticado. Interessante ressaltar que a própria Emenda Constitucional 19/1988 deu aplicabilidade ao princípio.

Vejamos o que diz a Constituição no art. 41, ao tratar da perda do cargo de um servidor público estável que seja considerado ineficiente em avaliações públicas de desempenho. Essa avaliação especial de desempenho mencionada pelo referido artigo é a aplicação do princípio da eficiência!

Em suma, não basta que o administrador público tenha uma atuação dentro da legalidade. É necessário que essa atuação produza resultados positivos, favoráveis aos fins do estado.

Vamos aproveitar o ensejo e esclarecer um ponto que pode ser uma dúvida de muitos de vocês. Trata-se da diferenciação entre 3 termos:

Eficiência, Eficácia e Efetividade

José dos Santos Carvalho Filho nos esclarece com maestria:

Eficiência, eficácia e efetividade são conceitos que não se confundem. A **eficiência** seria o **modo** pelo qual se exerce a função administrativa. A **eficácia** diz respeito aos **meios e instrumentos** empregados pelo agente. E a **efetividade** é voltada para os **resultados** de sua atuação

A eficiência, meu(minha) amigo(a), exige daqueles que irão aplicar os recursos públicos o exame da relação custo/benefício de sua atuação. Há uma necessidade de planejamento, indicando quais são as melhores opções. Para se obter atividades eficientes, é necessário que se faça o planejamento dos gastos públicos, a definição de metas e o exame dos custos necessários ao atingimento dessas metas.

Mas não é só a busca da **eficiência** que se deve fazer. Também é necessário que o administrador procure fazer um exame sob a ótica da **eficácia** e **efetividade** de sua atuação. Afinal, a Constituição de 1988 exige o controle da **economicidade** da atuação administrativa, nos termos do art. 70 e, por **economicidade**, devemos entender a harmonia entre **eficiência, eficácia e efetividade**.

Por eficácia, devemos entender o simples exame dos resultados. Assim, sendo realizada qualquer atividade estatal, deve-se examinar em que medida aquela atividade produziu benefícios para a coletividade.

O exame da **eficácia**, como aspecto da economicidade, dá especial importância aos resultados do exercício de qualquer atividade do Estado. Assim, o administrador deverá verificar quais resultados as atividades que desempenha geraram, e se isso trouxe algum benefício para a coletividade. Caso não haja benefícios, os responsáveis devem definir novos modelos ou estratégias.

A **efetividade**, por sua vez, só ocorrerá se os dois aspectos da economicidade mencionados anteriormente – eficiência e eficácia – tiverem sido cumpridos. Assim, pelo respeito à eficiência, devem ter sido definidas metas de atuação. Pela eficácia, presume-se que foram constatados resultados da atividade administrativa. Por fim, pela efetividade deve-se comparar as metas fixadas com os resultados efetivamente produzidos.

Muito bem. Com o princípio da eficiência concluímos os **5 princípios expressos no “caput” do art. 37 da Constituição**. É o célebre “**L.I.M.P.E.**”, sigla que todo estudante de Direito Administrativo imediatamente vincula a princípios.



Atenção!

Não são apenas esses cinco os princípios constitucionais do Direito Administrativo. Esses estão arrolados, de forma explícita, no art. 37, *caput*.

Mas há outros princípios administrativos que estão expressos na Constituição!

Sim, amigo(a), não estamos aqui falando de entendimento doutrinário, e sim do próprio texto constitucional! Vejamos que o art. 5º, inciso LV, assegura a todos

Art. 5º

LV – os litigantes, em processos judiciais ou administrativos, o contraditório e a ampla defesa.

Esses dois princípios, que caminham sempre de mãos dadas, foram impostos pela Constituição Federal a todos os agentes públicos que atuem em processos administrativos.

Princípios Expressos na Lei n. 9.794/1999

Contraditório e Ampla Defesa:

O **contraditório** diz respeito à comunicação dos atos dos processos, em tempo hábil à adoção de medidas do interesse das partes.

Esse princípio deve ser respeitado em todos os processos, sejam eles judiciais ou administrativos. Veja, por exemplo, o que ocorre no Processo Administrativo Disciplinar, na fase de Inquérito. O acusado será ouvido somente após a inquirição das testemunhas. Isso porque é necessário que seja concedido a esse acusado o direito de contraditar as testemunhas, pedir acareações, enfim... é necessário que ele seja comunicado de todos os atos processuais, em tempo suficiente para tomar as providências de seu interesse.

A **ampla defesa** diz o respeito ao direito dos interessados, em processos administrativos, de **se manifestarem antes da decisão**, além de utilizarem de todos os **meios de prova, desde que obtidas por meios lícitos**. Aqui temos a aplicação, nos processos administrativos, da **teoria dos frutos da árvore envenenada**⁹, prevista na Lei n. 9.784/1999, art. 30.

Outro aspecto importante acerca da aplicabilidade do **princípio da ampla defesa** a processos administrativos é que **não há a obrigatoriedade de defesa técnica** (por advogado).

⁹ A **teoria dos frutos da árvore envenenada** ("fruits of the poisonous tree", em inglês) é uma "metáfora legal". Ela determina que uma prova obtida por meios ilícitos acaba por viciar de ilicitude todas as provas que dela se originem. É o que se denomina "ilicitude por derivação".

A **Súmula Vinculante n. 5** determina que a ausência de defesa técnica nos Processos Administrativos Disciplinares (o que também se aplica a todos os demais processos administrativos) não gera a nulidade do processo. Fazer-se assistir por advogado, nos processos administrativos, é **um direito** dos interessados.

Por fim, vamos verificar a questão do **duplo grau de julgamento**.

– Existe o direito ao duplo grau de julgamento, na esfera administrativa, como inerente à ampla defesa?

– Seria assegurado o direito a recursos, nos processos administrativos, em obediência ao princípio da ampla defesa?

A resposta para ambos questionamentos é SIM. É assegurado o direito a recursos, e isso fica assegurado pela **Súmula Vinculante n. 21**, que julga inconstitucional a exigência de depósito prévio ou caução, como condição para a interposição de recurso administrativo. Isso se deve ao fato que a exigência de tal depósito viria a limitar o direito à ampla defesa.

Razoabilidade e Proporcionalidade

Razoabilidade: determina que o agente público, ao se deparar com situações em que a lei permite **discricionariedade** na atuação, deve fazer suas escolhas dentro de padrões médios de **aceitabilidade social**. Uma atuação razoável é uma atuação aceitável socialmente.

Esse princípio foi desenvolvido pelo Direito Administrativo para controlar a legitimidade dos atos administrativos. A razoabilidade se apresenta como um mecanismo de controle da discricionariedade administrativa e resume-se na seguinte expressão: **“adequação entre meios e fins”**.

No Direito Administrativo, o princípio da razoabilidade é aplicado em situações concretas, com o fim de definir se a solução adotada é compatível com as peculiaridades que o caso concreto comporta. A importância prática da razoabilidade está no fato de que ela permite o controle de legitimidade da discricionariedade administrativa. O exame de razoabilidade não significa invasão do mérito, pois a solução contrária à razoabilidade não é inconveniente ou inoportuna, e sim ilícita.

Proporcionalidade: intimamente relacionado à razoabilidade, sendo inclusive modernamente entendido como um de seus aspectos, também diz respeito à **adequação entre meios e fins**. A razoabilidade, entretanto, deve ser entendida em sentido amplo, enquanto a proporcionalidade é um mecanismo que se destina a conter o uso da imperatividade e do poder de polícia administrativa. Os atos administrativos devem ter consequências proporcionais aos motivos que ensejam à sua prática. As consequências dos atos não podem ser nem mais intensas nem menos intensas que os motivos que justificaram sua prática. A proporcionalidade é muito colocada em prática em caso de aplicação de penalidades. Assim, a penalidade não deve ser desproporcionalmente mais intensa ou menos intensa que a infração cometida.

Motivação

Mais uma vez vamos lançar mão da lição do professor Lucas Rocha Furtado:

Em regimes democráticos, em que o Estado atua de modo a atender às necessidades da população e de modo a realizar fins compatíveis com os direitos fundamentais e com a realização da Constituição, não se admite a prática de atos não motivados, não justificados.

O princípio da motivação impõe ao administrador o dever de **indicar os pressupostos de fato e de direito em que se fundamentou seu ato**. (Lei n. 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, VII). Dessa forma, o ato administrativo só será válido se trouxer, por escrito, a exposição dos fundamentos fáticos (circunstâncias) e fundamentos jurídicos que justificam sua prática.

A Lei n. 9.784/1999, além de mencionar explicitamente o princípio da motivação, em seu artigo 2º, dedicou um capítulo exclusivamente à motivação, tratando do tema no art. 50, que traz um rol exemplificativos de motivações obrigatórias. Vejamos:

CAPÍTULO XII

DA MOTIVAÇÃO

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

- I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
 - II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
 - III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
 - IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
 - V – decidam recursos administrativos;
 - VI – decorram de reexame de ofício;
 - VII – deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
 - VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
- § 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
- § 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
- § 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.

A motivação é mais um mecanismo de controle da Administração Pública. Ao motivar o ato, o administrador vincula-se aos motivos expostos. Se não houver correspondência entre o motivo alegado e a realidade, o ato pode ser anulado.

É oportuno que, ao tratar do princípio da motivação, façamos uma abordagem da **teoria dos motivos determinantes**, tema muito cobrado em provas de concursos. Vejamos:

Teoria dos Motivos Determinantes:

Para essa teoria, ao motivar o ato, *ainda que não fosse obrigado a fazê-lo*, o administrador se vincula ao motivo exposto. Se não houver conformidade entre o motivo e a motivação, o ato será nulo.

Curiosidade: a Teoria dos Motivos Determinantes nasceu no Direito Administrativo francês, através de Gaston Jèze¹⁰. Foi desenvolvida a partir de um caso de contencioso administrativo. O caso foi o seguinte: um servidor público foi exonerado sob a alegação de que ele próprio havia feito um pedido de desligamento. Esse servidor provou que nunca houvera feito o pedido, e sua exoneração foi anulada.

Segurança Jurídica

Esse princípio tem base constitucional, no art. 5º, XXXVI, que impede que a lei retroaja para afetar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.

É aplicável a todos os ramos do Direito, pois seu fundamento é garantir a previsibilidade das ações do Estado e, conseqüentemente, estabilidade, ordem e paz social, na medida em que impede que ocorram mudanças abruptas, sobressaltos e surpresas em consequência ações governamentais

A aplicação do princípio da segurança jurídica evita que as pessoas tenham surpresas com alterações nas leis ou nas condutas do Estado e, em relação ao Direito Administrativo, evita que novas interpretações da norma administrativa sejam aplicadas com efeitos retroativos.

É o que dispõe o art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/1999:

¹⁰ **Gaston Jèze** foi um acadêmico francês, Especialista em Finanças Públicas e Direito Administrativo, humanitário e ativista dos direitos humanos. Nasceu em Toulouse, em 2 de março de 1869 e morreu em de agosto de 1953, em Deauville.

Art. 2º

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: [...]

XIII- interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de **nova interpretação**".

Jurisprudência: O Supremo Tribunal Federal entende que a **segurança jurídica** é também **princípio constitucional** na posição de **subprincípio do Estado de Direito** (MS 24.268/MG).

Princípios Implícitos

Continuidade dos Serviços Públicos.

Diz respeito à **não interrupção da atividade** administrativa.

Em um primeiro momento, devemos nos fixar no seguinte raciocínio: A atividade da Administração deve ser ininterrupta.

Diante do grave inconveniente e dos problemas gerados pela interrupção da atividade administrativa, surgem algumas questões práticas que precisamos enfrentar:

1) Como fica o **direito de greve** dos agentes públicos?

Em primeiro lugar, devemos excluir da abrangência do direito de greve os **militares**. O art. 142 da Constituição veda expressamente o direito de sindicalização e de greve dos militares. De acordo com esse dispositivo constitucional, a vedação abrange os militares das forças armadas e também os policiais militares e bombeiros dos estados. Assim, greve de militares é inconstitucional!

Os servidores civis, por sua vez, têm assegurado pela Constituição, no art. 37, o direito de greve, a ser exercido nos termos e condições estabelecidos em **lei específica**.

Muito bem, ocorre que essa lei específica não foi editada até o presente momento. Passa-se à discussão acerca da natureza dessa norma constitucional. Seria ela uma norma de eficácia contida ou limitada? O **STF** entende que o direito de greve do servidor público civil é uma norma constitucional de eficácia limitada. Isso significa que, enquanto não houver a lei que regulamente o dispositivo previsto na constituição, o direito nele assegurado não pode ser exercido.

Em 2008, foram julgados, pela Corte Suprema, os Mandados de Injunção 670 e 712. A decisão do STF foi no sentido de que, até que seja editada a lei regulamentadora, aplicar-se-á aos servidores públicos a lei geral de greve, com ressalvas aos serviços essenciais.

Cabe ainda lembrar que nem sempre a paralisação da prestação de serviços públicos será ilícita. A própria lei que rege as concessões e permissões de serviços públicos – Lei n. 8.987/1995 – prevê hipóteses de paralisação legítima.

Vejamos:

Art. 6º

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

- I – motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,
- II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Autotutela

Antes de mais nada, deixe-me alertá-lo para o fato de que o Cespe já utilizou em provas a expressão “**princípio da sindicabilidade**”, como sinônimo de princípio da autotutela. Fique atento(a)!

Esse princípio determina que a administração exerce o controle sobre os próprios atos com a possibilidade de, independentemente de atuação do judiciário, anular os ilegais ou revogar os inconvenientes ou inoportunos (STF, Súmulas 346 e 473).

Além da jurisprudência, a Lei n. 9.784/1999, em seu artigo 53, trouxe o princípio para o direito positivo brasileiro. Vejamos:

Art. 53. A Administração **deve anular** seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e **pode revogá-los** por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.

Vale a pena ressaltar que, diante do que dispõe o art. 53, fica bem claro que a anulação do ato administrativo é um dever da administração, enquanto a revogação é uma prerrogativa.

No âmbito do direito privado, a anulação de um ato jurídico só pode ocorrer mediante intervenção judicial. Um particular não pode declarar nulo um ato jurídico, pois essa prerrogativa é privativa do Estado.

Já no âmbito do direito público, quando o Poder Público for parte em uma relação jurídica, ele tem a possibilidade de anular seus próprios atos ou contratos, independentemente de qualquer intervenção judicial. Em relação ao contraditório e ampla defesa, ressalte-se que só são necessários em caso de atos individuais, que afetam pessoas ou grupo de pessoas determinados.

A revogação dos atos administrativos é uma faculdade que decorre diretamente do princípio da autotutela e se relaciona a critérios de conveniência e oportunidade. Em razão da supremacia do interesse público, o Poder Público tem a faculdade de desfazer seus atos por motivo de conveniência ou oportunidade. É o que ocorreria, por exemplo, se, após conceder uma autorização a um particular, o Poder Público considerasse que tal ato deixou de ser conveniente ou oportuno e decidisse revogá-lo.

Devido Processo Legal Formal e Material

Esse princípio, previsto no art. 5º, LIV, da CF, tem aplicabilidade no Direito Administrativo, no que se refere à exigência que seja instaurado um processo administrativo que assegure as garantias do contraditório e ampla defesa, antes que o Poder Público tome qualquer decisão

Devemos observar que há dois aspectos do princípio, que são bem definidos:

- **Devido processo legal formal:** diz respeito ao rito a ser observado no processo, que deve ser pré-definido, sob pena de nulidade do processo.
- **Devido processo legal material:** exige que o processo seja concluído com uma decisão justa e proporcional (esse aspecto se confunde com o princípio da **proporcionalidade**).

Muito bem, amigo(a). Com isso concluímos a primeira parte de nossa aula. Vamos às questões de provas de concursos e, na sequência, passaremos ao Capítulo 2.

QUESTÕES DE CONCURSO – LISTA 1

1. (CESPE/2017/MP/RR/PROMOTOR SUBSTITUTO) De acordo com o entendimento do STF, no que se refere à inscrição de candidatos que possuam tatuagens gravadas na pele, não havendo lei que disponha sobre o tema, os editais de concursos públicos estão impedidos de restringi-la, com exceção dos casos em que essas tatuagens violem valores constitucionais.

2. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO) Acerca do Direito Administrativo, julgue o item que se segue.

Conforme a doutrina, diferentemente do que ocorre no âmbito do direito privado, os costumes não constituem fonte do Direito Administrativo, visto que a administração pública deve obediência estrita ao princípio da legalidade.

3. (CESPE/2017/PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/PROCURADOR MUNICIPAL/ADAPTADA) Em sentido objetivo, a administração pública se identifica com as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos e, em sentido subjetivo, com a natureza da função administrativa desempenhada.

4. (CESPE/2017/PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/PROCURADOR MUNICIPAL/ADAPTADA) Devido ao fato de regular toda a atividade estatal, o Direito Administrativo aplica-se aos atos típicos dos Poderes Legislativo e Judiciário

5. (CESPE/2017-PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/PROCURADOR MUNICIPAL/ADAPTADA) A respeito dos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o item abaixo.

Apesar de expressamente previsto na CF, o princípio da eficiência não é aplicado, por faltar-lhe regulamentação legislativa.

6. (CESPE/2017-PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/PROCURADOR MUNICIPAL/ADAPTADA) A respeito dos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o item abaixo.

Ao princípio da publicidade corresponde, na esfera do direito subjetivo dos administrados, o direito de petição aos órgãos da administração pública.

7. (CESPE/2017-PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/PROCURADOR MUNICIPAL/ADAPTADA) A respeito dos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o item abaixo.

O princípio da autoexecutoriedade impõe ao administrador o ônus de adequar o ato sancionatório à infração cometida.

8. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO) Acerca do Direito Administrativo, julgue os itens que se seguem.

Considerando os princípios constitucionais explícitos da administração pública, o STF estendeu a vedação da prática do nepotismo às sociedades de economia mista, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado.

9. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO) Acerca do Direito Administrativo, julgue os itens que se seguem.

A possibilidade de realização de obras para a passagem de cabos de energia elétrica sobre uma propriedade privada, a fim de beneficiar determinado bairro, expressa a concepção do regime jurídico-administrativo, o qual dá prerrogativas à administração para agir em prol da coletividade, ainda que contra os direitos individuais

10. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

Acerca do Direito Administrativo, julgue os itens que se seguem.

A regulação das relações jurídicas entre agentes públicos, entidades e órgãos estatais cabe ao Direito Administrativo, ao passo que a regulação das relações entre Estado e sociedade compete aos ramos do direito privado, que regulam, por exemplo, as ações judiciais de responsabilização civil do Estado.

11. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

Acerca da ética e da moralidade no serviço público, julgue os itens subsecutivos.

A conduta ética do servidor deve basear-se não somente na legalidade, mas também em ações fundamentadas na dignidade, no decoro, na eficácia e na consciência dos princípios morais.

12. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

Acerca da ética e da moralidade no serviço público, julgue os itens subsecutivos.

Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão

13. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

Com base no Decreto n. 1.171/1994, na Lei n. 8.112/1990 e na Lei n. 8.429/1992, julgue os próximos itens.

Qualquer servidor público está obrigado a manter conduta compatível com a moralidade administrativa e a cumprir as ordens de seus superiores, à exceção das que sejam manifestamente ilegais.

14. (CESPE/2016/TRE/PE/2016/CARGO 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) O princípio da continuidade dos serviços públicos

- a)** afasta a possibilidade de interrupção, ainda que se trate de sistema de remuneração por tarifa no qual o usuário dos referidos serviços esteja inadimplente.
- b)** diz respeito, apenas, a serviços públicos, não alcançando as demais atividades administrativas.
- c)** torna ilegal a greve de servidores públicos.
- d)** tem relação direta com os princípios da eficiência e da supremacia do interesse público.
- e)** impede a paralisação, ainda que a justificativa desta seja o aperfeiçoamento das atividades

15. (CESPE/2008/TJ-DFT) Acerca dos princípios explícitos e implícitos da administração pública, julgue os itens subsequentes.

A Constituição Federal faz menção expressa apenas aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

16. (CESPE/2008/TJ-DFT) Acerca dos princípios explícitos e implícitos da administração pública, julgue os itens subsequentes.

Diversos princípios administrativos, embora não estejam expressamente dispostos no texto da Constituição, podem ser dela deduzidos logicamente, como consequências inarredáveis do próprio sistema administrativo-constitucional.

17. (CESPE/2016/SEDF/CONHECIMENTOS BÁSICOS/CARGO 1, 3 A 26) A respeito dos princípios da administração pública e da organização administrativa, julgue o item a seguir.

Se uma autoridade pública, ao dar publicidade a determinado programa de governo, fizer constar seu nome de modo a caracterizar promoção pessoal, então, nesse caso, haverá, pela autoridade, violação de preceito relacionado ao princípio da impessoalidade

18. (CESPE/2016/SEDf/CONHECIMENTOS BÁSICOS/CARGO 1, 3 A 26) Em relação aos princípios da administração pública e à organização administrativa, julgue o item que se segue.

O administrador, quando gere a coisa pública conforme o que na lei estiver determinado, ciente de que desempenha o papel de mero gestor de coisa que não é sua, observa o princípio da indisponibilidade do interesse público.

19. (CESPE/2016/SEDf/CONHECIMENTOS BÁSICOS/CARGO 1, 3 A 26) Acerca dos princípios fundamentais que regem a administração pública brasileira, julgue o item a seguir.

Os princípios que regem a administração pública federal brasileira estão estabelecidos no Título I/Dos Princípios Fundamentais, da Constituição Federal de 1988.

20. (CESPE/2016/FUB) Acerca dos princípios fundamentais que regem a administração pública brasileira, julgue o item a seguir.

Entre esses princípios inclui-se aquele que autoriza que o administrador público federal, em determinadas situações, delegue competência para a prática de atos administrativos.

21. (CESPE/2016/FUB) No que diz respeito aos poderes e deveres dos administradores públicos, julgue o item que se segue.

O dever do administrador público de agir de forma ética e com boa-fé se refere ao seu dever de eficiência.

22. (CESPE/2016/FUB) Com relação à administração pública, julgue o item que se segue.

Como um dos princípios da administração pública brasileira, a publicidade destina-se a garantir a transparência dos atos dos agentes públicos.

23. (CESPE/2016/TCE-PA) Acerca de função administrativa e atos administrativos, julgue o item a seguir.

Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, o Estado somente poderá exercer sua função administrativa sob o regime de direito público.

24. (CESPE/2016/FUB) Acerca dos servidores públicos, dos poderes da administração pública e do regime jurídico-administrativo, julgue o item que se segue.

A supremacia do interesse público sobre o interesse particular, embora consista em um princípio implícito na Constituição Federal de 1988, possui a mesma força dos princípios que estão explícitos no referido texto, como o princípio da moralidade e o princípio da legalidade.

25. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA) Acerca do Direito Administrativo, julgue o item que se segue.

Considerando os princípios constitucionais explícitos da administração pública, o STF estendeu a vedação da prática do nepotismo às sociedades de economia mista, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado.

26. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA) cerca de administração pública, organização do Estado e agentes públicos, julgue o item a seguir.

O direito de petição é um dos instrumentos para a concretização do princípio da publicidade.

27. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA) No que se refere aos princípios da administração pública, julgue o item subsequente.

O princípio da publicidade viabiliza o controle social da conduta dos agentes administrativos

28. (CESPE/2016/TCE-PA) No que se refere aos princípios da administração pública, julgue o item subsequente.

O princípio da eficiência norteia essencialmente a prestação de serviços públicos à coletividade, sem impactar, necessariamente, rotinas e procedimentos internos da administração

29. (CESPE/2016/TCE-SC) O Tribunal de Contas de determinado estado da Federação, ao analisar as contas prestadas anualmente pelo governador do estado, verificou que empresa de publicidade foi contratada, mediante inexigibilidade de licitação, para divulgar ações do governo. Na campanha publicitária promovida pela empresa contratada, constavam nomes, símbolos e imagens que promoviam a figura do governador, que, em razão destes fatos, foi intimado por WhatsApp para apresentar defesa. Na data de visualização da intimação, a referida autoridade encaminhou resposta, via WhatsApp, declarando-se ciente. Ao final do procedimento, o Tribunal de Contas não acolheu a defesa do governador e julgou irregular a prestação de contas.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Dado o teor da campanha publicitária, é correto inferir que, na situação, se configurou ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade

30. (CESPE/2016/INSS) Julgue o item que se segue, acerca da administração pública. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente.

31. (CESPE/2016/INSS) Julgue o item que se segue, acerca da administração pública. Em decorrência do princípio da impessoalidade, as realizações administrativo-governamentais são imputadas ao ente público e não ao agente político.

32. (CESPE/2016/INSS) Julgue o próximo item, a respeito dos atos administrativos e dos princípios da Administração.

Em decorrência do princípio da autotutela, não há limites para o poder da administração de revogar seus próprios atos segundo critérios de conveniência e oportunidade.

33. (CESPE/2017/SERES/AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIARIA/SUPERIOR) Secretário de justiça e direitos humanos de determinado estado da Federação que publicar uma portaria e, na semana seguinte, revogá-la, em nova publicação, terá praticado ato revogatório com base no princípio da

- a)** Indisponibilidade
- b)** Moralidade
- c)** Autotutela
- d)** Eficiência
- e)** Supremacia do interesse público

34. (CESPE/2017/TCE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/ÁREA AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS/SUPERIOR) Com relação a agentes públicos, atos administrativos, poderes da administração pública e responsabilidade civil do Estado, julgue os itens subsequentes.

Fundamentada no poder de autotutela, desde que não esteja configurada a decadência do direito, poderá a administração anular atos sob o argumento de estes terem sido praticados com base em interpretação errônea verificada posteriormente.

35. (CESPE/2017/TCE/ANALISTA DE GESTÃO/ÁREA JULGAMENTO/SUPERIOR) No que concerne aos poderes e deveres da administração pública e aos princípios que regem o regime jurídico-administrativo, julgue os itens que se seguem.

A objetividade no atendimento do interesse público e a vedação à promoção pessoal de autoridades são exemplos da aplicação do princípio constitucional da impessoalidade.

36. (CESPE/2017/TCE/ANALISTA DE GESTÃO/ÁREA JULGAMENTO/SUPERIOR) No que concerne aos poderes e deveres da administração pública e aos princípios que regem o regime jurídico-administrativo, julgue os itens que se seguem.

Em razão do princípio do interesse público, não é possível que o poder público atenda aos interesses privados não estatais.

37. (CESPE/2017/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE SEGUNDA CATEGORIA/SUPERIOR) Jorge, servidor público federal ocupante de cargo de determinada carreira, foi, por meio administrativo, transferido para cargo de carreira diversa.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes à luz do entendimento dos tribunais superiores.

A forma de provimento do cargo público na referida situação — transferência para cargo de carreira diversa — foi inconstitucional, por violar o princípio do concurso público; cabe à administração pública, no exercício do poder de autotutela, anular o ato ilegal, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

38. (CESPE/2017/TRE-BA/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/SUPERIOR/ADAPTADA) A respeito da administração pública, julgue os itens a seguir. São princípios que regem a administração pública expressos na Constituição Federal de 1988: legalidade, indivisibilidade, moralidade, publicidade e eficiência.

39. (CESPE/2017/TRE-BA/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/SUPERIOR/ADAPTADA) A respeito da administração pública, julgue os itens a seguir. A avaliação de desempenho como condição para a aquisição de estabilidade do servidor público é um exemplo de aplicação do princípio da eficiência.

40. (CESPE/2017/TRE-BA/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/SUPERIOR/ADAPTADA) A respeito da administração pública, julgue os itens a seguir. A afronta a qualquer um dos princípios explícitos da administração pública pode configurar ato de improbidade administrativa.

41. (CESPE/2017/TRE-BA/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/SUPERIOR/ADAPTADA) A respeito da administração pública, julgue os itens a seguir. A moralidade administrativa é definida com base na concepção pessoal do agente público acerca da conduta administrativa considerada ética.

42. (CESPE/2017/TRE-BA/TÉCNICO) Determinado município, após celebrar com particulares contratos de promessa de venda e compra de glebas de sua propriedade, passou, sob a gestão do novo prefeito, a promover anulações contratuais porque os parcelamentos pactuados não estariam regularizados por não atenderem a requisitos legais.

Nessa situação hipotética, para obstar a pretensão do município, será adequado que o particular prejudicado invoque, em seu favor, o princípio da

- a)** Igualdade
- b)** Continuidade dos serviços públicos
- c)** Proporcionalidade
- d)** Moralidade
- e)** Confiança legítima

43. (CESPE/2017/TRE-BA/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL/SUPERIOR) Agente público que se utiliza de publicidade governamental com a finalidade exclusiva de se promover viola o princípio da

- a)** Eficiência
- b)** Moralidade
- c)** Autotutela
- d)** Publicidade
- e)** Motivação

44. (CESPE/2017/PROCURADOR MUNICIPAL/SUPERIOR/ADAPTADA) A respeito dos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o item.

Dado o princípio da autotutela, poderá a administração anular a qualquer tempo seus próprios atos, ainda que eles tenham produzido efeitos benéficos a terceiros.

45. (CESPE/2017/PROCURADOR MUNICIPAL/SUPERIOR/ADAPTADA) A respeito dos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o item.

Apesar de expressamente previsto na CF, o princípio da eficiência não é aplicado, por faltar-lhe regulamentação legislativa.

46. (CESPE/2017/PROCURADOR MUNICIPAL/SUPERIOR/ADAPTADA) A respeito dos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o item.

Ao princípio da publicidade corresponde, na esfera do direito subjetivo dos administrados, o direito de petição aos órgãos da administração pública.

47. (CESPE/2017/PROCURADOR MUNICIPAL/SUPERIOR/ADAPTADA) A respeito dos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o item.

O princípio de autoexecutoriedade impõe ao administrador o ônus de adequar o ato sancionatório à infração cometida.

48. (CESPE/2017/TRE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/NÍVEL SUPERIOR) O princípio da razoabilidade

a) se evidencia nos limites do que pode, ou não, ser considerado aceitável, e sua inobservância resulta em vício do ato administrativo.

b) incide apenas sobre a função administrativa do Estado.

c) é autônomo em relação aos princípios da legalidade e da finalidade.

d) comporta significado unívoco, a despeito de sua amplitude, sendo sua observação pelo administrador algo simples

e) pode servir de fundamento para a atuação do Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo.

GABARITO – LISTA 1

- | | |
|-------|-------|
| 1. C | 25. C |
| 2. E | 26. C |
| 3. E | 27. C |
| 4. E | 28. E |
| 5. E | 29. C |
| 6. C | 30. E |
| 7. E | 31. C |
| 8. C | 32. E |
| 9. C | 33. C |
| 10. C | 34. E |
| 11. C | 35. C |
| 12. E | 36. E |
| 13. C | 37. C |
| 14. d | 38. E |
| 15. E | 39. C |
| 16. C | 40. C |
| 17. C | 41. E |
| 18. C | 42. E |
| 19. E | 43. b |
| 20. C | 44. E |
| 21. E | 45. E |
| 22. C | 46. C |
| 23. E | 47. E |
| 24. C | 48. a |

QUESTÕES COMENTADAS

1. (CESPE/2017/MP/RR/PROMOTOR SUBSTITUTO) De acordo com o entendimento do STF, no que se refere à inscrição de candidatos que possuam tatuagens gravadas na pele, não havendo lei que disponha sobre o tema, os editais de concursos públicos estão impedidos de restringi-la, com exceção dos casos em que essas tatuagens violem valores constitucionais.

Certo.

O tema já provocou grandes debates. Até alguns anos atrás, possuir tatuagem e ser policial militar já foram duas opções excludentes. Não era possível escolher ambos, pois tatuagem era causa incontestável de reprovação no concurso da PM. Mudanças se operaram na sociedade e fazer uma tatuagem tornou-se uma conduta aceitável. Mas, apesar da mudança de visão social, os editais de concursos das Polícias Militares eram duros no sentido de restringir o acesso de candidatos tatuados. Dessa forma, o jovem era aprovado na prova, mas, quando era convocado para o exame médico, era reprovado com a justificativa de que ostentava uma tatuagem em seu corpo. Em consequência dessa rigidez, à medida que candidatos eram reprovados, vários recursos chegavam ao Judiciário, sob fundamento de que a decisão, em tese, ferira o direito de concorrerem a vaga de policiais militares. Até que um desses recursos provocou repercussão geral. Trata-se do caso de um candidato à vaga de soldado da PM/SP que recorreu da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, levando o caso até o Supremo Tribunal Federal.

No STF, foi reconhecida repercussão geral do Recurso Extraordinário 898450/SP, nos seguintes termos:

Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.

2. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO) Acerca do Direito Administrativo, julgue o item que se segue.

Conforme a doutrina, diferentemente do que ocorre no âmbito do direito privado, os costumes não constituem fonte do Direito Administrativo, visto que a administração pública deve obediência estrita ao princípio da legalidade.

Errado.

O costume é fonte de Direito em geral. Sendo a lei omissa, o juiz deve decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito (art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

O inciso III do artigo 100 do CTN mostra que as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas devem ser respeitadas. Logo, o costume deve também ser respeitado no âmbito do Direito Público, especificamente no Direito Tributário.

O costume também é fonte do Direito Administrativo, desde que se respeite o princípio da legalidade. Não se pode considerar válido, por exemplo, um costume que crie obrigação de pagamento ou direito a recebimento de uma quantia, pois, nesse caso, há a submissão ao princípio da reserva legal, ou seja, de estarem previstos em lei, além da necessidade de observância da lei orçamentária.

Podemos citar como exemplo um costume na Faculdade de Direito da USP, que os docentes de maior titulação e antiguidade escolhem a matéria que querem ministrar. O Regimento da USP não estabelece a forma de escolher as aulas a ministrar. Outorga-se competência ao departamento da atribuição da distribuição das aulas, mas não a forma como serão distribuídas. Logo, elas podem ser distribuídas de acordo com o costume na USP de antiguidade e titulação.

Direito costumeiro é o que “se irradia de repetição de atitudes humanas que o meio social fez regras jurídicas” (Miranda, Pontes. *Comentários ao CPC*. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense, 1996, tomo IV, p. 286). Isso mostra que o costume é fonte de direito e também no direito público, como no direito processual. O CPC não faz distinção em relação à matéria de Direito Público ou Privado.

Vejamos o que dizem os principais doutrinadores brasileiros:

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello¹¹ pondera que os defensores do costume no Direito Administrativo afirmam que

O Direito Administrativo se encontra em formação, com maior fundamento se abre ao costume campo de expansão, pois só uma parte dele está encerrada em normas jurídicas escritas, havendo amplo claro ainda não legislado para sua criação supletiva. De mais, há certos institutos que ainda não têm os seus contornos gizados na lei, e, então surge possibilidade efetiva para a ação esclarecedora do costume

Celso Bastos¹² assevera que

No Direito Administrativo, são bastante importantes, porque a Administração é resultante de práticas rotineiras e burocráticas, muitas vezes não calcadas propriamente em lei, mas, simplesmente, no hábito de agir de determinada forma” “Acontece que os costumes não possuem a característica de terem a sua validade consubstanciada no que dispõe a ordem jurídica, mas no fato de serem respeitados, de serem acolhidos como tais. Sendo assim, não se pode deixar de curvar à existência desses costumes.

¹¹ (Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, p. 19).

¹² Curso de direito administrativo, Celso Bastos editor, SP, 2002, p. 35.

José Cretella Jr. atribui ao costume “grande valor como fonte do Direito Administrativo.”

Franco Montoro¹³ ensina que

O costume se apresenta, pois, como verdadeira norma jurídica, cuja principal característica é ser criada espontaneamente pela consciência comum do povo e não editada pelo poder público”. Mais adianta, afirma que “igualmente, no Direito Administrativo, o costume, a praxe administrativa, as reiterações dos casos servem geralmente de elemento essencial à construção não só da doutrina, mas também da norma jurídica.

Hely Lopes Meirelles¹⁴ leciona que

No Direito Administrativo Brasileiro o costume exerce ainda influência, em razão da deficiência da legislação. A prática administrativa vem suprimindo o texto escrito, e, sedimentada na consciência dos administradores e administrados, a praxe burocrática passa a suprir a lei, ou atua como elemento informativo da doutrina

Luiz de Castro Neto¹⁵ diz que o costume é fonte de Direito Administrativo “quando preenche as omissões da lei”.

Diógenes Gasparini¹⁶ ensina que, no Direito Administrativo, o costume tem importância, “dada a deficiência da legislação nessa área do Direito Público. Supre, assim, a legislação, que sabemos ser notoriamente parca”

3. (CESPE/2017/PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/PROCURADOR MUNICIPAL/ADAPTADA) Em sentido objetivo, a administração pública se identifica com as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos e, em sentido subjetivo, com a natureza da função administrativa desempenhada.

¹³ Introdução à ciência do direito. 25ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 348/9

¹⁴ Direito administrativo brasileiro. 21ª ed. São Paulo, Malheiros, 1996, p. 37.

¹⁵ Fontes de direito administrativo. São Paulo, CTE, 1977, p. 87)

¹⁶ (Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, p. 19).

Errado.

O sentido objetivo da expressão “administração pública” se refere às atividades administrativas (O que faz?), enquanto o sentido subjetivo se relaciona com os sujeitos dessas atividades (quem faz?)

4. (CESPE/2017/PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/PROCURADOR MUNICIPAL/ADAPTADA) Devido ao fato de regular toda a atividade estatal, o Direito Administrativo aplica-se aos atos típicos dos Poderes Legislativo e Judiciário

Errado.

O Direito Administrativo é aplicável no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário, quando no exercício da função administrativa, que é atípica para esses Poderes e típica para o Poder Executivo.

5. (CESPE/2017/PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/PROCURADOR MUNICIPAL/ADAPTADA) A respeito dos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o item abaixo.

Apesar de expressamente previsto na CF, o princípio da eficiência não é aplicado, por faltar-lhe regulamentação legislativa.

Errado.

O princípio da eficiência, previsto no artigo 37, *caput*, já foi regulamentado por outros dispositivos constitucionais e legais. Exemplo é o artigo 41, da CF/1988, que teve incluído em seu § 1º, inciso III, que prevê a perda do cargo por servidor estável considerado inapto em avaliações periódicas de desempenho.

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I – Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II – Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

6. (CESPE/2017-PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/PROCURADOR MUNICIPAL/ADAPTADA) A respeito dos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o item abaixo.

Ao princípio da publicidade corresponde, na esfera do direito subjetivo dos administrados, o direito de petição aos órgãos da administração pública.

Certo.

Direitos subjetivos são aqueles que, quando surgem para o titular, geram em contrapartida uma obrigação a outrem. Assim, enquanto os particulares têm o direito subjetivo de peticionar ao Poder Público na defesa de seus direitos e interesses, a Administração deve guiar-se pelo princípio da publicidade, que exige transparência na atuação administrativa.

7. (CESPE/2017-PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/PROCURADOR MUNICIPAL/ADAPTADA) A respeito dos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o item abaixo.

O princípio da autoexecutoriedade impõe ao administrador o ônus de adequar o ato sancionatório à infração cometida.

Errado.

A autoexecutoriedade é a possibilidade conferida à Administração de fazer com que se cumpram suas decisões pelas vias administrativas, sem necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário.

8. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO) Acerca do Direito Administrativo, julgue os itens que se seguem.

Considerando os princípios constitucionais explícitos da administração pública, o STF estendeu a vedação da prática do nepotismo às sociedades de economia mista, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado.

Certo.

Em agosto de 2008, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula Vinculante n. 13, na tentativa de impedir o nepotismo em todos os órgãos do Estado, incluindo as estruturas do Poder Executivo e Legislativo, bem como as pessoas jurídicas da Administração Pública indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista). Estabelece a referida Súmula:

A nomeação de cônjuge, companheiro, ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta ou indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

9. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO) Acerca do Direito Administrativo, julgue os itens que se seguem.

A possibilidade de realização de obras para a passagem de cabos de energia elétrica sobre uma propriedade privada, a fim de beneficiar determinado bairro, expressa a concepção do regime jurídico-administrativo, o qual dá prerrogativas à administração para agir em prol da coletividade, ainda que contra os direitos individuais

Certo.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro¹⁷ ensina que

A expressão regime jurídico administrativo é reservada somente para abranger o conjunto de traços, de conotações que tipificam o Direito Administrativo, colocando a Administração Pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Basicamente pode-se dizer que o regime administrativo se resume a duas palavras apenas: prerrogativas e sujeições.

A autora ensina que

Ao mesmo tempo em que as **prerrogativas** colocam a Administração em posição de supremacia perante o particular, sempre com o objetivo de atingir o benefício da coletividade, as **restrições** a que está sujeita limitam a sua atividade a determinados fins e princípios que, se não observados, implicam desvio de poder e consequente nulidade dos atos da Administração. O conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a Administração e que não se encontram nas relações entre particulares constitui o **regime jurídico administrativo**. Muitas dessas prerrogativas e restrições são expressas sob a forma de **princípios** que informam o direito público e, em especial, o Direito Administrativo.

10. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO) Acerca do Direito Administrativo, julgue os itens que se seguem.

¹⁷ PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. *Direito administrativo*. 19ª edição. Editora Atlas. São Paulo, 2006.

A regulação das relações jurídicas entre agentes públicos, entidades e órgãos estatais cabe ao Direito Administrativo, ao passo que a regulação das relações entre Estado e sociedade compete aos ramos do direito privado, que regulam, por exemplo, as ações judiciais de responsabilização civil do Estado.

Errado.

A ação de responsabilização do Estado é prevista em norma constitucional, sendo regida pelo Direito Público.

11. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

Acerca da ética e da moralidade no serviço público, julgue os itens subsecutivos.

A conduta ética do servidor deve basear-se não somente na legalidade, mas também em ações fundamentadas na dignidade, no decoro, na eficácia e na consciência dos princípios morais.

Certo.

O enunciado da questão aponta corretamente os aspectos da moralidade administrativa. Como já vimos, a ética, o decoro e a moral convergem para dar os parâmetros da moralidade.

12. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

Acerca da ética e da moralidade no serviço público, julgue os itens subsecutivos.

Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão

Errado.

Talvez um candidato desatento tenha deixado passar em branco o erro do item. Verifique que, ao final do enunciado, o examinador afirma que ética e moral se referem a aspectos legais da vida **do cidadão**. Já vimos que a moralidade, como princípio, não é a mesma moral do senso comum. Portanto, errada a questão.

13. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/PROCURADOR DO MUNICÍPIO) Com base no Decreto n. 1.171/1994, na Lei n. 8.112/1990 e na Lei n. 8.429/1992, julgue os próximos itens.

Qualquer servidor público está obrigado a manter conduta compatível com a moralidade administrativa e a cumprir as ordens de seus superiores, à exceção das que sejam manifestamente ilegais.

Certo.

Sem problemas essa questão. A própria Lei n. 8.112/1990, que traça o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, no artigo 116, IV, afirma que o servidor está obrigado a obedecer às ordens de superiores hierárquicos, **SALVO** as manifestamente ilegais.

14. (CESPE/2016/TRE/PE/2016/CARGO 6/TÉCNICO JUDICIÁRIO/CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) O princípio da continuidade dos serviços públicos

- a)** afasta a possibilidade de interrupção, ainda que se trate de sistema de remuneração por tarifa no qual o usuário dos referidos serviços esteja inadimplente.
- b)** diz respeito, apenas, a serviços públicos, não alcançando as demais atividades administrativas.

- c) torna ilegal a greve de servidores públicos.
- d) tem relação direta com os princípios da eficiência e da supremacia do interesse público.
- e) impede a paralisação, ainda que a justificativa desta seja o aperfeiçoamento das atividades

Letra d.

A Supremacia do Interesse público inspira todos os demais princípios, enquanto a eficiência impõe a prestação da atividade administrativa de forma contínua, dentre outros aspectos.

- a) Errada.** A inadimplência do usuário é uma das possibilidades de interrupção lícita da prestação do serviço público, desde que previamente comunicado;
- b) Errada.** O princípio alcança todas as atividades administrativas, e não somente o serviço público propriamente dito.
- c) Errada.** A greve no serviço público é prevista na própria Constituição Federal. Apenas deve ser exercida nos termos da lei.
- e) Errada.** A própria Lei n. 8.987/1995, que rege a prestação de serviços públicos mediante concessão e permissão, prevê a possibilidade de interrupção da prestação, por razões de ordem técnica, substituição ou manutenção de equipamentos.

15. (CESPE/2008/TJ-DFT) Acerca dos princípios explícitos e implícitos da administração pública, julgue os itens subsequentes.

A Constituição Federal faz menção expressa apenas aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Errado.

Não há dúvidas que os cinco princípios previstos no artigo 37, *caput*, da CF/1988 não são os únicos expressamente previstos na Constituição.

Vide comentários no tópico “princípios constitucionais expressos”.

16. (CESPE/2008/TJ-DFT) Acerca dos princípios explícitos e implícitos da administração pública, julgue os itens subsequentes.

Diversos princípios administrativos, embora não estejam expressamente dispostos no texto da Constituição, podem ser dela deduzidos logicamente, como consequências inarredáveis do próprio sistema administrativo-constitucional.

Certo.

O item está absolutamente certo. É exatamente esse o raciocínio que devemos seguir, no que se refere ao tema princípios.

Capítulo 2

Poderes da Administração

Embora a palavra “PODER” transmita a ideia de faculdade, na verdade, devemos entendê-los aqui como poderes-deveres, que são conferidos à Administração Pública para que ela os exerça em benefício da coletividade. São irrenunciáveis, pelo fato de serem prerrogativas de autoridade, e só podem ser exercidos nos limites da lei.

Vejamos o que Hely Lopes Meirelles¹⁸ lecionou sobre isso: “se para o particular o poder de agir é uma faculdade, para o administrador público é uma obrigação de atuar, desde que apresente o ensejo de exercitá-lo em benefício da sociedade”.

Não há dúvidas que os poderes da Administração são prerrogativas conferidas pela lei ao administrador para que esse alcance o fim público da atividade administrativa. Por essa razão a doutrina é unânime em afirmar que tratam-se de poderes/deveres.

Vale a pena lembrar que a Lei n. 9.784/1999, quando trata da competência, no art. 11, dispõe que

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria...”

Vamos, então, passar à análise de cada um desses poderes:

- poder vinculado;
- poder discricionário;
- poder normativo ou regulamentar;
- poder hierárquico;
- poder disciplinar;
- poder de polícia.

Vinculação e Discricionariedade Administrativa

A professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro¹⁹ considera que, a rigor, não existe um “poder vinculado” ou um “poder discricionário”, assim considerados como poderes autônomos. Para ela, trata-se, na verdade, de características de outros poderes. Vejamos o que diz a célebre autora:

¹⁸ MEIRELLES, Hely Lopes, *Direito Administrativo Brasileiro*, p. 82.

¹⁹ Op. Cit.

Quanto aos chamados poderes discricionário e vinculado, não existem como poderes autônomos; a discricionariedade e a vinculação são, quando muito, atributos de outros poderes ou competências da Administração.

O chamado "poder vinculado", na realidade, não encerra "prerrogativa" do poder público, mas, ao contrário, dá ideia de restrição, pois, quando se diz que determinada atribuição da Administração é vinculada, quer-se significar que está sujeita à lei em praticamente todos os aspectos; o legislador, nessa hipótese, preestabelece todos os requisitos do ato, de tal forma que, estando eles presentes, não cabe à autoridade administrativa senão editá-lo, sem apreciação de aspectos concernentes à oportunidade, conveniência, interesse. Quanto aos chamados poderes discricionário e vinculado, não existem como poderes autônomos; a discricionariedade e a vinculação são, quando muito, atributos de outros poderes ou competências da Administração.

O chamado "poder vinculado", na realidade, não encerra "prerrogativa" do poder público, mas, ao contrário, dá ideia de restrição, pois, quando se diz que determinada atribuição da Administração é vinculada, quer-se significar que está sujeita à lei em praticamente todos os aspectos; o legislador, nessa hipótese, preestabelece todos os requisitos do ato, de tal forma que, estando eles presentes, não cabe à autoridade administrativa senão editá-lo, sem apreciação de aspectos concernentes à oportunidade, conveniência, interesse público, equidade. Esses aspectos foram previamente valorados pelo legislador

A discricionariedade, sim, tem inserida em seu bojo a ideia de prerrogativa, uma vez que a lei, ao atribuir determinada competência, deixa alguns aspectos do ato para serem apreciados pela Administração diante do caso concreto; ela implica liberdade a ser exercida nos limites fixados na lei. No entanto, não se pode dizer que exista como poder autônomo; o que ocorre é que as várias competências exercidas pela Administração com base nos poderes regulamentar, disciplinar, de polícia, serão vinculadas ou discricionárias, dependendo da liberdade, deixada ou não, pelo legislador à Administração Pública.

Lucas Furtado também segue essa linha. Veja o que ele diz:

A discricionariedade administrativa não corresponde propriamente a um poder da Administração Pública. A liberdade conferida pela lei para que o administrador adote a melhor solução para casos concretos com base em juízo de conveniência ou de oportunidade não corresponde ao exercício de potestade pública de modo que a terminologia "poder vinculado" e "poder discricionário" é mantida por mera tradição, mas não por acerto jurídico ou técnico.

E o autor segue em sua explicação:

A confusão e a equiparação da discricionariedade administrativa ou do exercício de atividades vinculadas aos poderes administrativos se devem ao fato de que o exercício dos poderes – de polícia, hierárquico, disciplinar e regulamentar – envolve, em alguns casos, o exercício de atividade vinculada e, em outras hipóteses, de atividade discricionária.

Pois bem. Embora eu me filie à corrente de Maria Sylvia Di Pietro, considerando mais adequado se falar em “ato vinculado” e “ato discricionário”, nosso objetivo nesse curso é sua aprovação no concurso e, diante disso, vamos adotar a terminologia “poder vinculado” e “poder discricionário”, pelo fato de terem sido assim abordados nos recentes editais de concursos. Mas, fica a advertência de que, terminologias à parte, o que importa saber é que, havendo ou não poder vinculado e poder discricionário, a consequência será que, dependendo do regramento do ato, teremos um ato discricionário ou um ato vinculado.

Feitas as necessárias considerações, vamos seguir com nosso estudo, tratando do “poder vinculado”.

Poder Vinculado

O Poder Vinculado ou Poder Regrado não é uma prerrogativa da administração, mas uma restrição. Ocorre que a Lei, ao prever o ato, preestabelece todos os requisitos e elementos necessários à validade desse, não deixando ao administrador nenhum juízo de conveniência ou oportunidade.

O legislador, ao elaborar a lei, já fez um juízo de valor sobre estes aspectos. Nesses casos, teremos um **ato vinculado ou regrado**, em que todos os seus elementos constitutivos serão vinculados.

Alexandre Mazza²⁰ afirma que “onde houver vinculação, o agente público é um simples executor da vontade legal. O ato resultante do exercício dessa competência é denominado ato vinculado”.

²⁰ Op. Cit.



Atenção!

A prova do Ministério Público/ES considerou CORRETA a assertiva: “Em se tratando de poder vinculado, a liberdade de ação do administrador é mínima, pois terá que se ater à enumeração minuciosa do Direito Positivo para realizá-lo eficazmente”.

Poder Discricionário

A discricionariedade está diretamente ligada à noção de liberdade. Sabemos que, diferentemente do que acontece com os particulares, para os quais a liberdade se liga à ideia de licitude (“ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei”), no Direito Administrativo, a liberdade de ação do administrador só ocorre quando a lei expressamente autoriza. Somente onde há lei e apenas nos limites da lei é lícito a um administrador público exercer a parcela de liberdade que lhe é atribuída. Seria absurdo pensar que, para o administrador público, a discricionariedade decorre da ausência de lei proibitiva. Pelo contrário, é a própria lei que, quando atribui competências, deixa margem para liberdade de escolha sobre a **oportunidade ou conveniência** na prática do ato. Quando isso ocorre, temos então um **ato discricionário**. Mas, repare que essa discricionariedade apenas ocorre **dentro de limites**, caso contrário, haveria **arbitrariedade**, que é a ação contrária ou além da lei.

Assim, retomando a lição da professora Maria Sylvia Di Pietro:

No exercício das várias competências, ora a Administração atua de forma vinculada, ora de forma discricionária, dependendo de haver ou não margem para a escolha do mais conveniente ou oportuno na prática do ato .

A própria lei vai dar esta margem. Haver ou não discricionariedade depende da liberdade deixada ou não pelo legislador à Administração Pública.



Atenção!

A prova do Ministério Público/ES considerou CORRETA a assertiva: “O poder discricionário não se exerce acima ou além da lei, senão como toda e qualquer atividade executória com sujeição a ela”.

Existe, por parte da doutrina, algumas discussões sobre onde se encontra justificativa para essa margem de discricionariedade. Nesse ponto, vale a pena verificar o que diz Celso Antônio Bandeira de Mello²¹:

- a) **Intenção deliberada do legislador:** uma corrente da doutrina entende que o legislador, intencionalmente, deixou margem ao administrador para que esse escolhesse a solução mais apropriada para atender a finalidade da lei.
- b) **Impossibilidade material de regradar todas as situações:** alguns autores entendem que seria impossível ao legislador prever todas as situações concretas passíveis de ocorrência quando o administrador estiver no exercício da função administrativa e, diante disso, seria mais razoável atribuir competências flexíveis que pudessem adaptar-se à realidade dos fatos.
- c) **Inviabilidade jurídica da supressão da discricionariedade:** outros autores defendem que na Tripartição de Poderes, o legislador não pode esgotar na lei todas as situações concretas relacionadas a assuntos administrativos, pois isso levaria à neutralização das atribuições do Poder Executivo e consequentemente a ruptura de sua independência funcional;

²¹ MELLO, Celso Antônio Bandeira de, *Curso de direito administrativo*. São Paulo: Malheiros

d) **Impossibilidade lógica de supressão da discricionariedade:** esse é considerado o mais importante fundamento da discricionariedade. Trata-se da impossibilidade lógica de o legislador excluir competências discricionárias, porque a margem de liberdade está justamente na imprecisão dos conceitos empregados pela lei para definir competências. Assim, toda vez que o legislador outorga uma competência, deve fazê-lo por meio de conceitos jurídicos, que podem ser precisos ou não. Se não houver uma precisão ou determinação clara do significado de certo conceito jurídico, inevitavelmente haverá discricionariedade por parte do aplicador da lei. Alexandre Mazza²² cita um exemplo interessante:

Assim, por exemplo, quando a lei afirma que a Administração deve proibir o uso de “trajes indecentes” em certos ambientes, a indeterminação inerente ao conceito de traje indecente abre margem de liberdade para o agente público avaliar em quais casos a proibição deve ser aplicada.

Podemos citar outros exemplos de “conceitos jurídicos indeterminados”:

- bons costumes;
- boa-fé;
- solução adequada;
- decisão razoável etc.

A conclusão a que se chega é que, diante dessa impossibilidade lógica de suprimir a discricionariedade surge a impossibilidade de se evitarem competências discricionárias, não tendo o legislador, como impedir, ao empregar conceitos jurídicos indeterminados, certa margem de liberdade de escolha, em alguns casos, por parte do administrador.

²² Op. Cit.

Avançando mais um pouco em nosso estudo do poder discricionário veremos que é unânime na doutrina a possibilidade de **controle judicial dos atos discricionários**.

Vamos compreender bem isso.

Primeiramente, cabe salientar que o **mérito administrativo** é o juízo da conveniência ou oportunidade para a prática de um ato. O Judiciário jamais irá penetrar nesse juízo, seja para verificar, questionar ou julgar se há conveniência ou oportunidade em determinada atividade administrativa, pois isso é da competência do administrador. Assim, mesmo que o Judiciário exerça controle sobre atos discricionários, as decisões judiciais devem se restringir à verificação de **legalidade e razoabilidade**, por parte do administrador, na eleição das prioridades. Trata-se, em última análise, de uma **revisão judicial de decisões violadoras de princípios administrativos**, e não de controle específico do mérito das decisões adotadas pela Administração Pública.

Para concluir esse tópico, vamos esclarecer o significado da expressão **“discricionariedade técnica”**. Alexandre Mazza nos informa que

A expressão “discricionariedade técnica” é utilizada para designar a **solução de questões que exijam conhecimento científico especializado**. Nesses casos, a Administração Pública é obrigada a tomar uma **decisão amparada em parecer técnico-profissional**. Exemplo: ordem de demolição fundamentada em laudo de renomado engenheiro civil atestando o comprometimento da estrutura da construção. Como a discricionariedade técnica envolve conhecimentos especializados, **a Administração fica vinculada à manifestação conclusiva do profissional consultado**. É por isso que os casos denominados de “discricionariedade técnica”, na verdade, **são hipóteses de vinculação administrativa**, não cabendo ao Poder Público adotar solução diferente da indicada pelo especialista.

Assim, decisão administrativa dessa natureza só pode ser impugnada, judicial ou administrativamente, com amparo em outro parecer técnico da lavra de profissional especializado na matéria.

Poder Regulamentar

Embora a atividade normativa seja exercida de forma típica pelo Poder Legislativo, existem situações em que o Poder Executivo tem a tarefa de expedir **regulamentos** para explicar a lei.

Nesse contexto é que encontraremos a atividade da administração pública denominada **poder regulamentar**, que vem a ser um **desdobramento do poder normativo**, esse sim, mais amplo, que abrange várias espécies de atos normativos gerais, tais como os regimentos, as instruções, deliberações e resoluções.

O poder normativo pode ser exercido por órgãos e entidades administrativas, enquanto o poder regulamentar é privativo do Chefe do Executivo.

Assim, por exemplo, as Agências Reguladoras podem expedir resoluções sobre temas relacionados a suas competências.

Maria Sylvia Di Pietro²³ faz uma ponderação sobre o poder regulamentar:

Normalmente, fala-se em poder regulamentar; preferimos falar em poder normativo, já que aquele não esgota toda a competência normativa da Administração Pública; é apenas uma de suas formas de expressão, coexistindo com outras, conforme se verá. Os atos pelos quais a Administração exerce o seu poder normativo têm em comum com a lei o fato de emanarem normas, ou seja, atos com efeitos gerais e abstratos.

Mais adiante, a autora adverte que

Insere-se, portanto, o poder regulamentar como uma das formas pelas quais se expressa a função normativa do Poder Executivo. Pode ser definido como o que cabe ao Chefe do Poder Executivo da União, dos Estados e dos Municípios, de editar normas complementares à lei, para sua fiel execução.

²³ Op. Cit.

Também devemos lembrar que **o poder regulamentar decorre do poder hierárquico**, na medida em que não é competência que possa ser exercida por qualquer agente público, mas pela autoridade máxima do Poder Executivo que, através de atos administrativos gerais e abstratos ou gerais e **concretos**, busca dar fiel execução à lei.

Vejamos mais uma observação bastante pertinente de Maria Sylvia Di Pietro sobre o tema que estamos estudando:

O poder regulamentar é privativo do Chefe do Executivo (art. 84, IV, da Constituição) e se exterioriza por meio de decretos. Ele somente se exerce quando a lei deixa alguns aspectos de sua aplicação para serem desenvolvidos pela Administração, ou seja, quando confere certa margem de discricionariedade para a Administração decidir a melhor forma de dar execução à lei. Se o legislador esgotou a matéria, não há necessidade de regulamento.

Além do decreto regulamentar, o poder normativo da Administração ainda se expressa por meio de resoluções, portarias, deliberações, instruções, editadas por autoridades que não o Chefe do Executivo; estabelecem normas que têm alcance limitado ao âmbito de atuação do órgão expedidor.

Há, ainda, os regimentos, pelos quais os órgãos estabelecem normas sobre o seu funcionamento interno.

Em todas essas hipóteses, o ato normativo não pode contrariar a lei, nem criar direitos, impor obrigações, proibições, penalidades que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (arts. 52, H, e 37, *caput*, da Constituição). Note-se que o Congresso Nacional dispõe agora de poder de controle sobre os atos normativos do Poder Executivo, podendo sustar os que exorbitem do poder regulamentar (art. 49, V).

Previsão Normativa do Poder Regulamentar

O art. 84, IV e VI da Constituição de 1988 atribui ao chefe do Poder Executivo competência, nos seguintes termos:

Art. 84 . Compete privativamente ao Presidente da República:

[...]

IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.

VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001)

Decreto Regulamentar e Decreto Autônomo

Já entendemos que, dentro das competências constitucionais, cabe exclusivamente ao chefe do Poder Executivo regulamentar as leis, para que essas sejam executadas corretamente. O instrumento utilizado para tal regulamentação é o **decreto regulamentar**, também denominado **regulamento executivo**.

Note bem: esse regulamento não pode ser delegado pelo Presidente da República, pois não se inclui no rol das competências delegáveis, previsto no parágrafo único do artigo 84.

Vejamos o que diz a Constituição.

Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República

IV – Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

Por outro lado, o inciso VI do artigo 84 da CF/1988 traz a previsão do **decreto autônomo**, introduzido no texto da Constituição com a EC n. 32/2001, que dá ao chefe do Poder Executivo a possibilidade de tratar, por decreto, de assuntos como organização e funcionamento da administração federal, se isso não importar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

VI – Dispor, mediante decreto, sobre:

- a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos
- b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

Também já vimos que, além dos decretos, que são de competência do chefe do Executivo, o **poder normativo** da Administração atua por outros atos normativos, com caráter geral e efeitos externos, tais como as **resoluções, portarias, deliberações e instruções**.

Entenda que esses atos normativos da Administração Pública apenas se assemelham à norma legal, já que também têm a característica de generalidade e abstração. Entretanto, nunca se admitirá que um ato normativo venha a contrariar a lei, nem criar direitos, obrigações, penalidades, proibições que nela não estejam previamente dispostos, pois isso significaria ofensa ao princípio da legalidade.

Miguel Reale²⁴ nos traz uma lição importantíssima:

Os atos legislativos não diferem dos regulamentos ou de certas sentenças por sua natureza normativa, mas sim pela originariedade com que instauram situações jurídicas novas, pondo o direito e, ao mesmo tempo, os limites de sua vigência e eficácia, ao passo que os demais atos normativos explicitam ou complementam as leis, sem ultrapassar os horizontes da legalidade.

Assim, o poder normativo é a competência dada pela Lei ao Poder Executivo para o exercício da função legislativa, de forma atípica. Trata-se de um poder/dever, que deve ser exercido dentro dos limites legais.

– Caso se verifique omissão no cumprimento dessa tarefa de editar regulamentos, o que acontece?

²⁴ REALE, Miguel, *Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Forense

– A própria Constituição Federal prevê alguns **Remédios Constitucionais**, aplicáveis em caso de omissão.

Vejamos:

- a) **Mandado de injunção:** é cabível sua impetração, desde que a falta norma regulamentadora tornar inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, cidadania (art. 5º LXXXI).
- b) **Arguição de inconstitucionalidade por omissão:** está prevista no art. 103, § 2º, da Constituição Federal. Tem um âmbito restrito que o mandado de injunção, é cabível quando há omissão de medida necessária para tornar efetiva norma constitucional. O STF é competente para julgar e dar ciência ao Poder competente, para que este supra a omissão em 30 dias.

Muito bem, já vimos os remédios constitucionais cabíveis, no caso de omissão do Executivo, no cumprimento de seu dever de exercer o poder regulamentar.

Assim, em caso de omissão relativa ao dever de editar atos normativos, o ordenamento jurídico apresenta instrumentos hábeis a trazer solução para a falta do ato.

Por outro lado, qual a consequência de possíveis “excessos” no exercício do poder regulamentar? Pois bem, se o chefe do Executivo exorbitar em seu poder regulamentar, a própria Constituição, a fim de sanar o excesso, confere competência ao Poder Legislativo para **sustar o ato eivado de vício**. Faz sentido, pois sabemos que a função legislativa é típica do Poder Legislativo, e o Executivo a exerce, através do seu poder regulamentar, como uma função atípica. Logo, se o Executivo exorbitar no uso desse poder, o Legislativo exercerá o controle externo, a fim de aparar os excessos.

Vejamos o que dispõe o art. 49, V, da CF/1988:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

[...]

V – Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

Tudo certinho até aqui?

Ok! Então, vamos ao próximo tópico.

Poder Hierárquico

Dirigir, ordenar, coordenar, dar ordens e impor limites, bem como distribuir tarefas, escalonar funções, rever a atuação de seus agentes, ou ainda delegar e avocar atribuições são manifestações do poder hierárquico.

O poder hierárquico é a atividade da administração pública destinada a estabelecer a **relação de subordinação** entre seus agentes, na medida em que distribui e estabelece as funções dos órgãos públicos. São atribuições decorrentes do poder hierárquico:

- **editar atos**, com o objetivo de ordenar a atuação dos órgãos subordinados (são **atos de efeitos internos**, que não se confundem com os regulamentos);
- **dar ordens** aos subordinados;
- **controlar** permanentemente a atividade dos órgãos subordinados, devendo **anular atos** ilegais e podendo **revogar** os atos por razões de conveniência e oportunidade, **avocar*** e **delegar**** atribuições.

***Avocar:** chamar a si atribuições originalmente atribuídas a um subordinado, desde que não se refira a competência exclusiva. A avocação está prevista nos art. 15 da Lei n. 9.784/1999.

****Delegar:** conferir a outro agente atribuições que lhe seriam originalmente atribuídas. A delegação está prevista nos art. 12 e seguintes da Lei n. 9.784/1999.

Poder Disciplinar

É o poder que a Administração Pública possui para apurar infrações e aplicar penalidades funcionais aos agentes públicos e às pessoas que estão de alguma forma subordinadas à disciplina administrativa, como é o caso dos que contratam com o Poder Público.



Atenção!

As sanções aplicadas aos particulares não sujeitos à disciplina interna da administração não encontram fundamento no poder disciplinar, e sim no poder de polícia.

O poder disciplinar é discricionário em certos momentos, pois vão existir situações em que não há como o legislador preestabelecer de forma rígida todas as regras para a apuração da infração e aplicação da penalidade. Mas, de qualquer forma, não vamos confundir essa discricionariedade como total liberdade de opção. Por exemplo, a Administração não tem liberdade de escolha entre punir e não punir, pois, ao tomar conhecimento da irregularidade, a apuração dessa deverá ocorrer e, se for constatada a falta disciplinar, a penalidade deverá ser aplicada.

Por fim, cumpre ressaltar que **poder hierárquico e poder disciplinar não se confundem**. Ambos estão intimamente ligados, um complementando o outro, e ambos dando a sustentação à organização administrativa, porém possuem contornos bem definidos.

Poder de Polícia

Aqui estamos diante de uma atividade da administração Pública que, ao limitar ou disciplinar o exercício dos direitos, interesses ou liberdades individuais, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público. Seu **fundamento** é a **supremacia do interesse público sobre o privado**.

Conceito de Poder de Polícia

O **conceito** de poder de polícia está no **art. 78 do Código Tributário Nacional**, e isso se deve ao fato de ser o exercício deste poder um dos fatos geradores das **taxas** (espécies de tributos) cobradas pelo Poder Público.

Vamos ver como o CTN conceitua o poder de polícia.

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

[...]

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.



Atenção!

Fica a dica: dos poderes da Administração Pública, o único que está diretamente relacionado à geração de tributos é o poder de polícia.

A doutrina conceitua poder de polícia como sendo “a atividade do Estado que consiste em limitar o exercício de direitos individuais em benefício do interesse público”.

Polícia Administrativa e Polícia Judiciária

Sabe-se que o poder de polícia do Estado pode incidir em duas áreas de atuação: a judiciária e a administrativa. Podemos apontar como a principal distinção entre essas áreas o caráter que predomina na atividade, sendo que a **polícia administrativa tem uma** atuação predominantemente **preventiva**, ao passo que a **polícia judiciária é predominantemente repressiva**.

Mas, tenha em mente que essa distinção não é taxativa. Trata-se apenas de características predominantes. Tanto a polícia administrativa quanto a polícia judiciária atuam em alguns momentos de forma preventiva e, em outras circunstâncias, adotarão medidas repressivas.

Feitos esses esclarecimentos, vamos agora passar a uma análise mais apurada das duas áreas de atuação do poder de polícia:

Política Administrativa

Aqui a atividade da Administração Pública inicia-se e exaure-se em seu próprio âmbito de atuação. É executada por órgãos administrativos de caráter fiscalizador e será regida pelo Direito Administrativo. A atividade de polícia administrativa incide sobre bens, direitos ou atividades. Tem caráter eminentemente preventivo, no intuito de evitar que o dano aconteça. Mas, em alguns casos, atua de forma repressiva, diante de condutas irregulares dos administrados (exemplo típico é a aplicação de multas de trânsito).

Principais Ramos da Polícia Administrativa:

- polícia de trânsito;
- polícia sanitária;
- polícia de costumes;

- polícia de edificações;
- polícia de comunicações;
- polícia marítima, aérea e de fronteiras;
- polícia rodoviária e ferroviária.

Polícia Judiciária

Apesar de ser atividade administrativa, prepara a atuação da função jurisdicional penal, executada por órgãos de segurança pública. Rege-se pelo direito penal, incidindo sobre pessoas. Tem natureza eminentemente repressiva, destinando-se a responsabilização penal do indivíduo.

Atributos do Poder de Polícia

Por atributos vamos entender as **características predominantes** deste poder, que não necessariamente estão presentes em todos os atos. São eles:

1. Discricionariedade: consiste na opção de escolha, por parte da administração, dos meios mais adequados ao exercício do poder de polícia. A discricionariedade está presente em grande número de medidas, autorizando um juízo acerca da conveniência e oportunidade da atividade.

Um bom exemplo de ato discricionário, no exercício de poder de polícia, é a **autorização de uso de bem público**.



Atenção!

Pode haver situações em que a própria lei determina a adoção de medidas, previamente estabelecidas, sem qualquer liberdade de escolha. Quando isso ocorre, o ato será vinculado como, por exemplo, as licenças para conduzir veículos e para construir.

2. Autoexecutoriedade: Aqui temos a possibilidade efetiva de a administração exercer imediatamente seus atos, sem recorrer antes ao Poder Judiciário. É o que ocorre, por exemplo, nos casos de apreensão de mercadorias. Em situações como essa não teria sentido a administração ter que aguardar a aprovação prévia do Judiciário para a consecução do ato.



Atenção!

A autoexecutoriedade só existirá quando a lei assim o determinar. Trata-se, na verdade, de excepcionalidade, pois dá ao administrador grande margem de liberdade relativa à limitação ou mesmo supressão de direitos dos particulares, sendo desnecessária a apreciação judicial. Por essa razão, alguns atos que manifestam o poder de polícia, como as multas de trânsito, por exemplo, estão excluídos da autoexecutoriedade, que só podem ser executadas por via judicial.

3. Exigibilidade: a doutrina adverte que se trata de um desdobramento da autoexecutoriedade, que ocorre quando são utilizados **meios indiretos de coerção** (exemplo: multas diárias por mora no cumprimento das obrigações) para dar executoriedade aos atos.

Maria Sylvia Di Pietro traz uma lição extraída do direito francês, que esclarece bem esse ponto.

Vejamos:

Autoexecutoriedade (que os franceses chamam de executoriedade apenas) é a possibilidade que tem a Administração de, com os próprios meios, pôr em execução as suas decisões, sem precisar recorrer previamente ao Poder Judiciário.

Alguns autores desdobram o princípio em dois: a exigibilidade (*privilège du préalable*) e a executoriedade (*privilège d'action d'office*). O *privilège du préalable* resulta da possibilidade que tem a Administração de tomar decisões executórias, ou seja, decisões que dispensam a Administração de dirigir-se preliminarmente ao juiz para impor a obrigação ao administrado. A decisão administrativa impõe-se ao particular ainda contra a sua concordância; se este quiser se opor, terá que ir a juízo.

O *privilège d'action d'office* consiste na faculdade que tem a Administração, quando já tomou decisão executória, de realizar diretamente a execução forçada, usando, se for o caso, da força pública para obrigar o administrado a cumprir a decisão.

Pelo atributo da exigibilidade, a Administração se vale de meios indiretos de coação.

Cite-se, como exemplo, a multa; ou a impossibilidade de licenciamento do veículo enquanto não pagas as multas de trânsito.

Pelo atributo da autoexecutoriedade, a Administração compele materialmente o administrado, usando meios diretos de coação. Por exemplo, ela dissolve uma reunião, apreende mercadorias, interdita uma fábrica.

A autoexecutoriedade não existe em todas as medidas de polícia. Para que a Administração possa se utilizar dessa faculdade, é necessário que a lei a autorize expressamente, ou que se trate de medida urgente, sem a qual poderá ser ocasionado prejuízo maior para o interesse público. No primeiro caso, a medida deve ser adotada em consonância com o procedimento legal, assegurando-se ao interessado o direito de defesa, agora previsto expressamente no artigo 52, inciso LV, da Constituição. No segundo caso, a própria urgência da medida dispensa a observância de procedimento especial, o que não autoriza a Administração a agir arbitrariamente ou a exceder-se no emprego da força, sob pena de responder civilmente o Estado pelos danos causados (cf. art. 37, § 62, da Constituição), sem prejuízo da responsabilidade criminal, civil e administrativa dos servidores envolvidos.

Em resumo, pode-se dizer que a exigibilidade está presente em todas as medidas de polícia, mas não a executoriedade (*privilège d'action d'office*).

Interessante, não é mesmo?

4. Coercibilidade: é a imposição imperativa do ato de polícia aos destinatários, com **emprego da força pública**, se necessário, em caso de resistência do administrado.

Pois bem, amigo(a). Esses são os atributos do poder de polícia mencionados pela maioria da doutrina. Fique atento(a) em relação à **exigibilidade**, que vem sendo cobrada em provas como um atributo, embora se configure um desdobramento da autoexecutoriedade.

Agora gostaria de abordar mais uma característica do poder de polícia. Há uma minoria doutrinária que ainda menciona outro atributo para o poder de polícia: **"atividade negativa"**.

Conforme disse, esse atributo não é mencionado por parte da doutrina, mas aqueles que o fazem alegam que, devido ao fato de o poder de polícia praticamente nunca buscar uma ação por parte dos administrados, e sim a abstenção de determinadas condutas, a regra é que esse se limita a impor restrições, que se configuram em obrigações de não fazer. Daí ser uma **atividade negativa**, ou seja, aquela que **impõe uma obrigação de não fazer**.

Fica mencionado, embora não seja comum essa abordagem em provas de múltipla escolha.

Muito bem, caro(a) aluno(a). Já vimos os atributos do poder de polícia. Agora vamos avançar mais um pouco em nosso estudo.

Limitações ao Poder de Polícia

São impostos alguns limites ao exercício do poder de polícia, em respeito aos **direitos do cidadão e liberdades públicas** asseguradas pela Constituição Federal e pelas leis.

A doutrina aponta regras, que devem ser obedecidas pela Administração Pública quando no exercício do poder de polícia, objetivando não suprimir os direitos individuais. Tais regras são:

1. Necessidade: a atividade de polícia só pode ser adotada a fim de proteger o interesse público contra possíveis ameaças

2. Proporcionalidade: deve ser observada sempre a relação entre a limitação ao direito individual e o prejuízo que se procura evitar. Se a limitação ao direito individual não for a medida adequada a evitar o prejuízo, esta não deve ser adotada.

3. Eficácia: a medida deve ser adequada para impedir efetivamente o dano.

O art. 78, do CTN, em seu parágrafo único, estabelece os parâmetros para o regular exercício do poder de polícia, como sendo o exercício por autoridade competente, observância dos limites da lei e devido processo legal e **inexistência de abuso de poder**.

Art. 78.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, **sem abuso ou desvio de poder**.

Abuso de Poder

Trata-se de uma expressão utilizada em sentido genérico, pois comporta duas modalidades:

- a) **Excesso de poder:** defeito dos atos relacionado à **competência do sujeito**. Ocorre quando o agente pratica um ato que não se inclui entre suas atribuições legais.
- b) **Desvio de poder:** defeito relacionado à **finalidade**. Ocorre quando o agente, embora competente, pratica o ato visando fim diverso do interesse público (beneficiar ou prejudicar alguém, por exemplo).

Com isso, concluímos nossa aula 2.

Vamos agora à nossa bateria de exercícios, para completar o estudo do tema.

QUESTÕES DE CONCURSO – LISTA 2

1. (CESPE/FUB/AUDITOR) Acerca dos poderes administrativos, julgue o item que se segue.

O exercício do poder de polícia é delegável a pessoas jurídicas de direito privado.

2. (CESPE/2017/PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/PROCURADOR MUNICIPAL/COM ADAPTAÇÕES) Em relação aos poderes e deveres da administração pública, julgue o item que se segue:

É juridicamente possível que o Poder Executivo, no uso do poder regulamentar, crie obrigações subsidiárias que viabilizem o cumprimento de uma obrigação legal.

3. (CESPE/2017/PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/PROCURADOR MUNICIPAL/ADAPTADA) Em relação aos poderes e deveres da administração pública, julgue o item que se segue:

De acordo com o STF, ao Estado é facultada a revogação de ato ilegalmente praticado, sendo prescindível o processo administrativo, mesmo que de tal ato já tenham decorrido efeitos concretos.

4. (CESPE/2017/PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/PROCURADOR MUNICIPAL/COM ADAPTAÇÕES) Em relação aos poderes e deveres da administração pública, julgue o item que se segue:

De acordo com o STF, é possível que os guardas municipais acumulem a função de poder de polícia de trânsito, ainda que fora da circunscrição do município.

5. (CESPE/2017/PREFEITURA DE BELO HORIZONTE/PROCURADOR MUNICIPAL/COM ADAPTAÇÕES) Em relação aos poderes e deveres da administração pública, julgue o item que se segue:

Do poder disciplinar decorre a atribuição de revisar atos administrativos de agentes públicos pertencentes às escalas inferiores da administração.

6. (CESPE/PC/PE/DELEGADO 2016/ADAPTADA) Acerca dos poderes e deveres da administração pública, julgue o item abaixo.

A autoexecutoriedade é considerada exemplo de abuso de poder: o agente público poderá impor medidas coativas a terceiros somente se autorizado pelo Poder Judiciário.

7. (CESPE/PC/PE/DELEGADO 2016/ADAPTADA) Acerca dos poderes e deveres da administração pública, julgue o item abaixo.

À administração pública cabe o poder disciplinar para apurar infrações e aplicar penalidades a pessoas sujeitas à disciplina administrativa, mesmo que não sejam servidores públicos.

8. (CESPE/PC/PE/DELEGADO 2016/ADAPTADA) Acerca dos poderes e deveres da administração pública, julgue o item abaixo.

Poder vinculado é a prerrogativa do poder público para escolher aspectos do ato administrativo com base em critérios de conveniência e oportunidade; não é um poder autônomo, devendo estar associado ao exercício de outro poder.

9. (CESPE/PC/PE/DELEGADO 2016/ADAPTADA) Acerca dos poderes e deveres da administração pública, julgue o item abaixo.

Faz parte do poder regulamentar estabelecer uma relação de coordenação e subordinação entre os vários órgãos, incluindo o poder de delegar e avocar atribuições.

10. (CESPE/PC/PE/DELEGADO 2016/ADAPTADA) Acerca dos poderes e deveres da administração pública, julgue o item abaixo.

O dever de prestar contas aos tribunais de contas é específico dos servidores públicos; não é aplicável a dirigente de entidade privada que receba recursos públicos por convênio.

11. (CESPE/PC-PE/DELEGADO/2016/ADAPTADA) A fiscalização ambiental de determinado estado da Federação verificou que a água utilizada para o consumo dos hóspedes de um hotel era captada de poços artesianos. Como o hotel não tinha a outorga do poder público para extração de água de aquífero subterrâneo, os fiscais lavraram o auto de infração e informaram ao gerente do hotel que lacrariam os poços artesianos, conforme a previsão da legislação estadual. O gerente resistiu à ação dos fiscais, razão pela qual policiais militares compareceram ao local e, diante do impasse, o gerente, acompanhado do advogado do hotel, e os fiscais foram conduzidos à delegacia local. O advogado alegou que os fiscais teriam agido com abuso de autoridade, uma vez que o poder público estadual não teria competência para fiscalizar poços artesianos, e requereu ao delegado de plantão a imediata liberação do gerente e o registro, em boletim de ocorrência, do abuso de poder por parte dos fiscais.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item abaixo, considerando as regras e princípios do Direito Administrativo:

Agentes de fiscalização não possuem poder de polícia, que é exclusivo dos órgãos de segurança pública. Por essa razão, os fiscais não poderiam entrar no hotel, propriedade privada, sem o acompanhamento dos policiais militares.

12. (CESPE/PC-PE/DELEGADO/2016/ADAPTADA) A fiscalização ambiental de determinado estado da Federação verificou que a água utilizada para o consumo dos hóspedes de um hotel era captada de poços artesianos. Como o hotel não tinha a outorga do poder público para extração de água de aquífero subterrâneo, os fiscais lavraram o auto de infração e informaram ao gerente do hotel que lacrariam os poços artesianos, conforme a previsão da legislação estadual. O gerente resistiu à ação dos fiscais, razão pela qual policiais militares compareceram ao local e, diante do impasse, o gerente, acompanhado do advogado do hotel, e os fiscais foram conduzidos à delegacia local. O advogado alegou que os fiscais teriam agido com abuso de autoridade, uma vez que o poder público estadual não teria competência para fiscalizar poços artesianos, e requereu ao delegado de plantão a imediata liberação do gerente e o registro, em boletim de ocorrência, do abuso de poder por parte dos fiscais.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item abaixo, considerando as regras e princípios do Direito Administrativo:

A fiscalização estadual agiu corretamente ao aplicar o auto de infração: o hotel não poderia fazer uso de poço artesiano sem a outorga do poder público estadual. Contudo, os fiscais somente poderiam lacrar os poços se dispusessem de ordem judicial, razão pela qual ficou evidente o abuso de poder.

13. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA-CE/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

Com relação a processo administrativo, poderes da administração e serviços públicos, julgue o item subsecutivo.

O exercício do poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo da União, dos estados, do DF e dos municípios.

14. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA-CE) Com relação a processo administrativo, poderes da administração e serviços públicos, julgue o item subsecutivo.

Situação hipotética: Um secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais motivados por ideologia partidária. Assertiva: Nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder, na modalidade excesso de poder, já que atos de remoção de servidor não podem ter caráter punitivo

15. (CESPE/2017/PC-GO/DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO) De acordo com a legislação e a doutrina pertinentes, o poder de polícia administrativa pode ser exercido por órgão que também exerça o poder de polícia judiciária.**16.** (CESPE/2017/SED-DF/ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL-DIREITO E LEGISLAÇÃO) José, chefe do setor de recursos humanos de determinado órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação de servidores em concurso de promoção.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

O veículo normativo adequado para a edição do referido ato é o decreto.

17. (CESPE/2017/SED-DF/ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL-DIREITO E LEGISLAÇÃO) José, chefe do setor de recursos humanos de determinado órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação de servidores em concurso de promoção.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A edição do referido ato é exemplo de exercício do poder regulamentar.

18. (CESPE/2017/SED-DF/ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL-DIREITO E LEGISLAÇÃO) Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no serviço público que beneficiaram, diretamente, amigo(a) seus. A competência para a edição do referido ato normativo seria de Pedro, superior hierárquico de Mauro. Os servidores que se sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção apresentaram recurso quinze dias após a data da publicação do resultado.

Nessa situação hipotética, Mauro não agiu com abuso de poder.

19. (CESPE/ 2016/TCE-PA/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO) O Congresso Nacional aprovou uma reforma administrativa proposta pelo presidente da República que reduziu o número de ministérios. Nesse contexto, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência Social foram fundidos, tornando-se Ministério do Trabalho e Previdência Social. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A referida reforma administrativa poderia ter se materializado com a edição de decreto autônomo, em decorrência do poder regulamentar do presidente da República.

20. (CESPE/2016/TJ-AM/JUIZ SUBSTITUTO/ADAPTADO) Os poderes administrativos são prerrogativas outorgadas aos agentes públicos para a consecução dos interesses da coletividade. A respeito desses poderes, julgue o item abaixo

O pagamento de multa aplicada em decorrência do poder de polícia não pode configurar condição para que a administração pratique outro ato em favor do interessado.

21. (CESPE/2016/TJ-AM/JUIZ SUBSTITUTO/ADAPTADO) Os poderes administrativos são prerrogativas outorgadas aos agentes públicos para a consecução dos interesses da coletividade. A respeito desses poderes, julgue o item abaixo

O poder restritivo da administração, consubstanciado no poder de polícia, não se limita pelos direitos individuais.

22. (CESPE/2016/TJ-AM/JUIZ SUBSTITUTO/ADAPTADO) Os poderes administrativos são prerrogativas outorgadas aos agentes públicos para a consecução dos interesses da coletividade. A respeito desses poderes, julgue o item abaixo

O poder vinculado refere-se à faculdade de agir atribuída ao administrador.

23. (CESPE/2016/TJ-AM/JUIZ SUBSTITUTO/ADAPTADO) Os poderes administrativos são prerrogativas outorgadas aos agentes públicos para a consecução dos interesses da coletividade. A respeito desses poderes, julgue o item abaixo

Entre os poderes administrativos incluem-se o poder disciplinar, o poder regulamentar e o poder jurídico.

24. (CESPE/2016/TJ-AM/JUIZ SUBSTITUTO/ADAPTADO) Os poderes administrativos são prerrogativas outorgadas aos agentes públicos para a consecução dos interesses da coletividade. A respeito desses poderes, julgue o item abaixo

O Poder regulamentar é a prerrogativa concedida à administração pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação

25. (CESPE/2016/DPE-RN/DEFENSOR PÚBLICO/ADAPTADA) Com relação aos poderes da administração pública e aos poderes e deveres dos administradores públicos, julgue o item abaixo. A cobrança de multa constitui exemplo de exceção à autoexecutoriedade do poder de polícia, razão por que o pagamento da multa cobrada não pode se configurar como condição legal para que a administração pública pratique outro ato em favor do interessado.

26. (CESPE/2016/DPE-RN/DEFENSOR PÚBLICO/ADAPTADA) Com relação aos poderes da administração pública e aos poderes e deveres dos administradores públicos, julgue o item abaixo. A Autorização administrativa consiste em ato administrativo vinculado e definitivo segundo o qual a administração pública, no exercício do poder de polícia, confere ao interessado consentimento para o desempenho de certa atividade.

27. (CESPE/2016/DPE-RN/DEFENSOR PÚBLICO/ADAPTADA) Com relação aos poderes da administração pública e aos poderes e deveres dos administradores públicos, julgue o item abaixo.

Desvio de finalidade é a modalidade de abuso de poder em que o agente público atua fora dos limites de sua competência, invadindo atribuições cometidas a outro agente.

28. (CESPE/2016/DPE-RN/DEFENSOR PÚBLICO/ADAPTADA) Com relação aos poderes da administração pública e aos poderes e deveres dos administradores públicos, julgue o item abaixo. No exercício do poder regulamentar, é conferida à administração pública a prerrogativa de editar atos gerais para complementar a lei, em conformidade com seu conteúdo e limites, não podendo ela, portanto, criar direitos e impor obrigações, salvo as excepcionais hipóteses autorizativas de edição de decreto autônomo.

29. (CESPE/2016/DPE-RN/DEFENSOR PÚBLICO/ADAPTADA) Com relação aos poderes da administração pública e aos poderes e deveres dos administradores públicos, julgue o item abaixo.

Decorre do sistema hierárquico existente na administração pública o poder de delegação, segundo o qual pode o superior hierárquico, de forma irrestrita, transferir atribuições de um órgão a outro no aparelho administrativo.

30. (CESPE/2016/DPU/CARGO 9) Tendo como referência as normas do Direito Administrativo, julgue o próximo item.

Constitui manifestação do poder disciplinar da administração pública a aplicação de sanção a sociedade empresarial no âmbito de contrato administrativo.

31. (CESPE/2016/DPU/CARGO 9) Tendo como referência as normas do Direito Administrativo, julgue o próximo item.

A interdição de restaurante por autoridade administrativa de vigilância sanitária constitui exemplo de manifestação do exercício do poder de polícia.

32. (CESPE/2016/DPU/ANALISTA TÉCNICO ADMINISTRATIVO) Acerca da organização administrativa da União, da organização e da responsabilidade civil do Estado, bem como do exercício do poder de polícia administrativa, julgue o item que se segue. A edição de ato normativo constitui exemplo do exercício do poder de polícia pela administração pública.

33. (CESPE/2015/TCU/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO) No que se refere a administração pública, órgão público e competência administrativa, julgue o item abaixo.

O poder de polícia e os serviços públicos são exemplos de atividades que integram o conceito de administração pública sob o critério material.

34. (CESPE/2015/TCU/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO) À luz da jurisprudência do STJ julgue o item abaixo, no que se refere aos poderes da administração pública.

No exercício do poder discricionário, a administração pública pode aferir o momento oportuno para a abertura de concurso público, porém, com fundamento no mesmo poder, não pode ela cancelar certame em andamento, em razão de critérios de conveniência e oportunidade.

35. (CESPE/2015/TCU/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO) À luz da jurisprudência do STJ julgue o item abaixo, no que se refere aos poderes da administração pública.

O poder-dever da administração pública de punir as faltas cometidas por servidores públicos é imprescritível e demanda prévia apuração em processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

36. (CESPE/2015/TCU/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO) À luz da jurisprudência do STJ julgue o item abaixo, no que se refere aos poderes da administração pública.

Um dos pressupostos para o exercício do poder de polícia é a ocorrência de violação individual a determinada limitação administrativa, hipótese em que a administração pública poderá valer-se de meios indiretos de coação como a imposição de multa, providência esta que não será possível nas hipóteses de violações massificadas.

37. (CESPE/2015/TCU/PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO) À luz da jurisprudência do STJ julgue o item abaixo, no que se refere aos poderes da administração pública.

A administração pública, considerando o interesse público e com fundamento no poder discricionário, pode atribuir nova lotação a servidor público, hipótese em que se admite que a motivação do ato seja posterior à remoção.

38. (CESPE/2015/TJ-PB/JUIZ) No que se refere aos princípios informativos e aos poderes da administração pública, julgue o item abaixo

Como a delegação de competência se assenta no poder hierárquico da administração pública, cujo pressuposto é a relação de subordinação entre órgãos e agentes públicos, é inadmissível a delegação de competência fora da linha vertical de subordinação e comando.

39. (CESPE/2015/TJ-PB/JUIZ) No que se refere aos princípios informativos e aos poderes da administração pública, julgue o item abaixo

No exercício do poder disciplinar, a administração pública pode impor sanção administrativa a servidor, sendo vedado ao Poder Judiciário, segundo jurisprudência, perquirir a motivação nesse caso.

40. (CESPE/2017/SED-DF/CARGOS 1 A 9) No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte.

O poder de polícia administrativo é uma atividade que se manifesta por meio de atos concretos em benefício do interesse público. Por conta disso, a administração pode delegar esse poder a pessoas da iniciativa privada não integrantes da administração pública.

41. (CESPE/2017/SED-DF/CARGOS 1 A 9) No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte.

A administração, ao editar atos normativos, como resoluções e portarias, que criam normas estabelecedoras de limitações administrativas gerais, exerce o denominado poder regulamentar.

42. (CESPE/2017/SED-DF/CARGOS 1 A 9) Acerca dos poderes administrativos, julgue o item que se segue.

O âmbito de incidência do poder disciplinar da administração pública está restrito aos servidores públicos.

43. (CESPE/2017/SED-DF/CARGOS 1 A 9) No tocante aos poderes administrativos, julgue o seguinte item.

A relação entre a administração direta e as entidades que integram a administração indireta pressupõe a existência do poder hierárquico entre ambas.

44. (CESPE/2017/SED-DF/CARGOS 1 A 9) Acerca dos poderes administrativos, julgue o item que se segue.

No Brasil, apenas excepcionalmente se admite ato normativo primário no exercício do poder regulamentar da administração pública.

45. (CESEPE/2016/TCE-SC/CONHECIMENTOS BÁSICOS/TODOS OS CARGOS) Com base na doutrina e nas normas de Direito Administrativo, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Diante da ausência de Maria, servidora pública ocupante de cargo de nível superior, João, servidor público ocupante de cargo de nível médio, recém-formado em Economia, elaborou determinado expediente de competência exclusiva do cargo de nível superior ocupado por Maria.

Assertiva: Nessa situação, o servidor agiu com abuso de poder na modalidade excesso de poder.

46. (CESPE/2015/STJ/ANALISTA) No tocante aos poderes administrativos, julgue o seguinte item.

O poder de polícia dispõe de certa discricionariedade, haja vista o poder público ter liberdade para escolher, por exemplo, quais atividades devem ser fiscalizadas para que se proteja o interesse público.

47. (CESPE/2015/STJ/ANALISTA) No tocante aos poderes administrativos, julgue o seguinte item.

No tocante aos poderes administrativos, julgue o seguinte item.

O desvio de finalidade é uma espécie de abuso de poder em que o agente público, apesar de agir dentro dos limites de sua competência, pratica determinado ato com objetivo diverso daquele pautado pelo interesse público.

48. (CESPE/2015/FUB/AUDITOR) Acerca dos poderes administrativos, julgue o item que se segue.

Decorrente do poder hierárquico, a avocação, por um órgão, de competência não exclusiva atribuída a outro órgão que lhe seja subordinado é excepcional e exige motivos relevantes e devidamente justificados.

49. (CESPE/2016/DPU/TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS) No que se refere aos poderes da administração pública e aos serviços públicos, julgue o item subse-
cutivo.

Configura-se desvio de poder ou de finalidade quando o agente atua fora dos limites de suas atribuições, ou seja, no caso de realizar ato administrativo não incluído no âmbito de sua competência.

50. (CESPE/2016/TCE/PA/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO) Acerca dos servidores públicos, dos poderes da administração pública e do regime jurídico-adminis-
trativo, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: O proprietário de determinado restaurante recebeu notificação na qual constava a determinação de que a obra que havia sido irregularmente realizada na calçada do referido estabelecimento, para a colocação de mesas, teria de ser demolida. **Assertiva:** Nesse caso, decorrendo o prazo sem cumprimento da ordem, a administração poderá promover a demolição sob o manto da autoexecutoriedade dos atos administrativos e do poder de polícia.

51. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/CE/PROCURADOR DO MUNICÍPIO) O exercício do poder de polícia reflete o sentido objetivo da administração pública, o qual se refere à própria atividade administrativa exercida pelo Estado

52. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/CE/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

O exercício do poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo da União, dos estados, do DF e dos municípios.

53. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/CE/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

Nos termos da jurisprudência do STF, caso um particular interponha recurso administrativo contra uma multa de trânsito, por se tratar do exercício do poder de polícia pela administração, a admissibilidade do recurso administrativo dependerá de depósito prévio a ser efetuado pelo administrado

54. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/CE/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

A atividade de fiscalização ambiental é típico ato administrativo que expressa o poder de polícia, pois diz respeito à restrição, à limitação, ao condicionamento e à ordenação de atividades desempenhadas por particulares.

55. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/CE/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

O exercício do poder de polícia visa à proteção do interesse da coletividade ou do Estado, razão pela qual não se submete ao controle pelo Poder Judiciário.

56. (CESPE/2017/TRE-PE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/ADAPTADA)

Julgue o item abaixo acerca do poder hierárquico.

Decorre do poder hierárquico o poder de revisão, por superior, dos atos praticados por subordinado.

57. (CESPE/2017/TRE-PE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/ADAPTADA)

Julgue o item abaixo acerca do poder hierárquico.

A disciplina funcional guarda relação com o poder disciplinar, não se ligando ao poder hierárquico.

58. (CESPE/2017/TRE-PE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/ADAPTADA)

Julgue o item abaixo acerca do poder hierárquico.

A avocação é regra ampla e geral cuja difusão deve ser estimulada em prol da eficiência.

59. (CESPE/2017/TRE-PE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/ADAPTADA)

Julgue o item abaixo acerca do poder hierárquico.

A hierarquia administrativa é restrita ao Poder Executivo.

60. (CESPE/2017/TRE-PE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/ADAPTADA)

Julgue o item abaixo acerca do poder hierárquico.

Subordinação e vinculação, como decorrências do poder hierárquico, são institutos que se confundem e que se caracterizam pelo controle que se dá no âmbito de um mesmo ente.

GABARITO

1. E	24. C	47. C
2. C	25. E	48. C
3. E	26. E	49. E
4. E	27. E	50. C
5. E	28. C	51. C
6. E	29. E	52. C
7. C	30. C	53. C
8. E	31. C	54. C
9. E	32. E	55. E
10. E	33. C	56. C
11. E	34. E	57. E
12. E	35. E	58. E
13. C	36. E	59. E
14. E	37. C	60. E
15. C	38. E	
16. E	39. E	
17. E	40. E	
18. E	41. E	
19. E	42. E	
20. E	43. E	
21. E	44. C	
22. E	45. C	
23. E	46. C	

QUESTÕES COMENTADAS

51. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/CE/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

O exercício do poder de polícia reflete o sentido objetivo da administração pública, o qual se refere à própria atividade administrativa exercida pelo Estado

Certo.

Com efeito, o sentido objetivo, funcional ou material da expressão administração pública deve ser entendido como as ATIVIDADES administrativas (o que é realizado pela Administração) . Nesse sentido, vamos encontrar serviços públicos, atividade de polícia e intervenção no domínio econômico.

52. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/CE/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

O exercício do poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo da União, dos estados, do DF e dos municípios.

Certo.

O poder normativo, exercido no âmbito de toda a Administração Pública, é mais genérico, e diz respeito à prerrogativa da Administração de emitir comandos genéricos e abstratos, com força obrigatória. Um exemplo desses atos normativos são as Resoluções, os Regimentos Internos e as Instruções Normativas.

Já o poder Regulamentar, privativo do chefe do Poder Executivo, está previsto no art. 84, incisos IV e VI, da Constituição Federal. Através de Regulamentos Executivos ou Regulamentos Autônomos o Chefe do Executivo busca explicitar as Leis ou ainda emite comandos gerais sobre temas relacionados ao funcionamento da Administração Pública (a extinção de cargos públicos vagos, por exemplo)

53. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/CE/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

Nos termos da jurisprudência do STF, caso um particular interponha recurso administrativo contra uma multa de trânsito, por se tratar do exercício do poder de polícia pela administração, a admissibilidade do recurso administrativo dependerá de depósito prévio a ser efetuado pelo administrado

Certo.

Súmula Vinculante 21

É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

54. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/CE/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

A atividade de fiscalização ambiental é típico ato administrativo que expressa o poder de polícia, pois diz respeito à restrição, à limitação, ao condicionamento e à ordenação de atividades desempenhadas por particulares.

Certo.

O conceito de poder de polícia, explícito no art. 78 do Código Tributário Nacional, inclui entre as atividades do poder de polícia exatamente as mencionadas na questão.

Vejamos:

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

55. (CESPE/2017/PREFEITURA DE FORTALEZA/CE/PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

O exercício do poder de polícia visa à proteção do interesse da coletividade ou do Estado, razão pela qual não se submete ao controle pelo Poder Judiciário.

Errado.

O Poder Judiciário pode ser chamado a exercer o controle da Administração no que se refere ao poder de polícia, inclusive preventivamente. Um exemplo seria o ajuizamento de um Mandado de Segurança Preventivo. Ademais, atos administrativos que violem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade podem ser anulados por decisão judicial, ainda que esses atos sejam discricionários.

56. (CESPE/2017/TRE-PE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/ADAPTADA)

Julgue o item abaixo acerca do poder hierárquico.

Decorre do poder hierárquico o poder de revisão, por superior, dos atos praticados por subordinado.

Certo.

O poder hierárquico possibilita que os superiores hierárquicos exerçam o controle dos atos praticados por seus subordinados, inclusive no que se refere aos recursos eventualmente interpostos contra decisões.

57. (CESPE/2017/TRE-PE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/ADAPTADA)

Julgue o item abaixo acerca do poder hierárquico.

A disciplina funcional guarda relação com o poder disciplinar, não se ligando ao poder hierárquico.

Errado.

Ao contrário do que afirma a questão, a disciplina funcional guarda estreita relação com o poder hierárquico. Alguns autores inclusive afirmam que o poder disciplinar é decorrência do poder hierárquico.

58. (CESPE/2017/TRE-PE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/ADAPTADA)

Julgue o item abaixo acerca do poder hierárquico.

A avocação é regra ampla e geral cuja difusão deve ser estimulada em prol da eficiência.

Errado.

A própria Lei n. 9.784/1999, ao dispor sobre a avocação em seu art. 15, estabelece que será admitida, em caráter excepcional e com a devida justificação a avocação temporária de competência atribuída originariamente a uma órgão subordinado. Não se deve ver essa medida como regra, mas como exceção.

59. (CESPE/2017/TRE-PE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/ADAPTADA)

Julgue o item abaixo acerca do poder hierárquico.

A hierarquia administrativa é restrita ao Poder Executivo.

Errado.

A hierarquia administrativa pode se fazer presente em qualquer dos Poderes, desde que se esteja diante da função administrativa. A título de exemplo, vejamos o que ocorre no âmbito do Poder Judiciário, quando compete ao Presidente de um Tri-

bunal autorizar as férias dos juízes. Sabe-se que a independência funcional é uma das garantias da magistratura. Entretanto, quando se está diante de atribuições administrativas, há escalonamento hierárquico.

60. (CESPE/2017/TRE-PE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/ADAPTADA)

Julgue o item abaixo acerca do poder hierárquico.

Subordinação e vinculação, como decorrências do poder hierárquico, são institutos que se confundem e que se caracterizam pelo controle que se dá no âmbito de um mesmo ente.

Errado.

Absolutamente errado esse item. Subordinação não se confunde com vinculação. Podemos citar como exemplo o que ocorre com as Administrações Públicas direta e indireta. As entidades descentralizadas, embora estejam vinculadas à administração direta, a ela não se subordinam hierarquicamente. Gozam de autonomia gerencial, financeira e administrativa. O que existe é apenas um controle finalístico, ou de resultados; tanto que já está pacificado na jurisprudência que não cabe recurso hierárquico próprio dirigido a órgão da administração direta contra decisão proferida por autoridade de entidade descentralizada.
